

**А.В. ПТУШЕНКО**

**Доктор юридических наук**

**Профессор**

**Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка  
Вице-президент Международного Университета гуманитарных наук**

# **ПРАВОВЕДЕНИЕ**

## **УЧЕБНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ**

---

### **Введение**

Как пишут в современных учебниках, сегодня Россия переживает сложные времена, и роль права в связи с этим возрастает. И это верно.

Неверно всё остальное — источники права, государство и право, структура права, закон и право. И главное, — что такое правоведение. Некоторые авторы учебников, по названию посвященных именно правоведению, на деле о нём не вспоминают вовсе, пересказывая действующее законодательство. Например, учебник под редакцией Пугинского.

Более того, в среде «ортодоксальных юристов» бытует ошибочное мнение, будто бы правоведение — это не для будущего профессионального юриста, а для студентов всех смежных специальностей, которым нужно лишь общее знакомство с правом. Поэтому курс правоведения выливается в этакое беглое обозрение «отстоя» с краткими комментариями к «злобе дня» текущего законодательства. При этом между законом и правом не делается необходимого различия.

**Настоящий учебник предлагает принципиально иной взгляд.**

Мы исходим из убеждения, что правоведение — наука о Праве. То есть не анализ быстротекущих законов, многие из которых — неправовые, а исследование правовых проблем, методологии построения Права, философии Права, соотношения Права и закона, ошибок законодательства. На наш взгляд, предмет права вовсе не сводится к взглядам на Право какого-либо «текущего» государства — ибо само государство обязано жить по праву, а не по сиюминутным, лоббирующим чьи-то шкурные интересы нормам. Утверждение, что государство и право неразрывны — плод недоразумения: государство действительно не может без права, но из этого вовсе не вытекает, что право не может существовать без государства. Говорят, право нуждается в силовом «обеспечении» со стороны государства. Это досадное заблуждение. В государственном «обеспечении» нуждаются законы. Право нуждается в одном — в абсолютной логичности и системности его создателей. И если закон занят деталями, то для Права важнее общие принципы и концепции.

Мы полагаем неверными и представления о Гражданском обществе как о некоем «сухом остатке» при вычитании государства из Общества. Общество — система более высокого порядка, государство — подсистема Общества. При этом нам не важно, что сегодняшнее российское государство не дотягивает до такого положения: предмет правоведения — не текущие обстоятельства жизни Общества, а их потребное («идеальное») состояние. Именно этим и отличается Правоведение от изучения действующих законов.

Знатор действующих законов — законник. Право же — предмет исследования правоведа. Поэтому именно будущий профессиональный юрист должен в совершенстве знать науку о Праве.

Профессиональный юрист должен знать не только историю Права, но и различия в подходах к основным его проблемам. Квалифицированный правоведа должен хорошо владеть формальной логикой, методологией системного анализа и уметь применять следствия

теоремы Гёделя к теории Права. Он должен понимать значение экологии как синтетической науки об эколого-экономико-правовых объектах. Он должен знать о значении космического права и о роли самой космонавтики в жизни будущего человечества.

Правовед должен быть широко образованным человеком. Он должен почаще вспоминать максиму Мартина Лютера: «Юрист, если он только юрист, — жалкая вещь!».

И не забывать слова Бернарда Шоу: «Двуногое, объявившее себя политиком, не заслуживает звания человека!».

## **1. Предмет курса «Правоведение»**

Многие учебники не считают нужным сформулировать определение собственного предмета. Часто это проходит незамеченным, поскольку вместо правоведения предлагается беглое рассмотрение некоторых частей Права: теории права и государства, гражданского права, административного права и т.п. При этом излагается всего лишь действующее на данный момент законодательство. Изложение ведётся в предположении, что право как раз и состоит в содержании законов. Какая-либо критика этих законов не допускается. Хотя большинство из них такой критики заслуживает и подчас демонстрирует яркие примеры не только юридической, но и логической и даже грамматической безграмотности. Уже этого достаточно, чтобы отвергнуть устоявшиеся подходы к правоведению.

Чисто юридические вузы считают правоведение чем-то ниже их собственного достоинства. Правоведение преподают в неюридических вузах и даже в средней школе. Официальный подход сводится к тому, что студента следует учить некоему усреднённому взгляду, — «отстою», полностью игнорирующему не только различия в подходах к сложным проблемам права, но и явные недоработки и нелепости, которыми изобилуют Конституция, кодексы и рядовые законы. Наименее осмыслены представления о Гражданском Обществе и правовом государстве, о самоуправлении, о сущности собственности, о системной сущности юридического лица, об интеллектуальной собственности, о компьютерном праве и о многом другом.

Никого не трогает, что при таком подходе к обучению, возникает неразрешимая педагогическая проблема. Обученные «отстою» ученики, будут продолжать учить «отстою» — и так из поколения в поколение. Пока общество полностью не деградирует.

Преподавание правоведения в школе нужно приветствовать. Но ещё важнее преподавать его «чистому» юристу. Чтобы он убоился собственного соответствия максиме Лютера.

**Сегодня необходим учебник принципиально иного толка.** Как его назвать — отдельный вопрос. Можно было бы оставить в покое устоявшееся, к сожалению, в ошибочном понимании слово «правоведение» и назвать учебник, например, так: «Общая теория права». Но опыт показывает, что это будет понято неправильно. Сегодня принято рассматривать «Теорию государства и права». И это исказит представление об общей теории права — считается (хотя это и неверно), что теория права неотрывна от теории государства. Но главное — настоятельно необходимо исключить типовую ошибку в понимании слова «правоведение». Это очень важно с принципиальных позиций, когда речь пойдёт о системном соотношении Общества и государства, о причинно-следственных связях Права и закона.

Поэтому оставим название «Правоведение», но постараемся обосновать его правильное понимание.

Прибегнем к доказательству по аналогии.

Существует в вузовской практике предмет «науковедение». Что это такое? Это наука о Науке. То есть это не поверхностный анализ каких-то (как правило, более понятных многочисленным авторам одного учебника) конкретных законов природы; это не «совокупность частных наук» — это краткое изложение общих принципов, парадигм, концепций и методологий Науки. Причём не только современной. Но и прошлой. Но и

будущей — в идеальном представлении. Иначе говоря, Науковедение изучает Науку с большой буквы, оставляя локальные конкретные «текущие» законы частным локальным наукам, формирующим узкого специалиста.

Точно такой же должна быть и наука о Праве. То есть правоведение.

Конечно, само право, и даже вытекающие из него законы, исследуются в курсе правоведения. Но именно исследуются: анализируются их базовые принципы, логические и юридические обоснования рассматриваемых положений, методология доказательств истинности и эффективности компонентов системы права — без какого-либо смешения анализа права с анализом сиюминутных законов, лоббирующих некие частные (подчас антиобщественные и противоправные) интересы.

Даже курс «Право» недопустимо строить только как инфантильное копание в экскрементах государства. Это — удел адвокатов и историков права. И, разумеется, коррумпированных чиновников. В отличие от них всех, Правовед — исследователь и критик права, установитель критериев эффективности и показателей совершенства взаимодействия подразделов (подсистем) права, установитель требований к методологии законотворчества, определитель соответствия текущего законодательства требованиям права. Правоведение формирует «направляющие косинусы» для законодателя. Правоведение — прерогатива **Концептуальной** власти, которой в стратегическом плане должны быть подчинены три остальные ветви государства — судебная, законодательная, исполнительная (в порядке их важности для Общества и объёма делегированных народом полномочий). При этом все ветви — прежде всего, исполнительная — в подлинно демократическом обществе должны быть только представительными. В Конституции РФ по этому поводу написана глупость: «В совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти» (ст.95), что равнозначно заявлению «стола бывают письменные и деревянные». Это есть классический пример классификации по разным основаниям. По одному основанию, власть подразделяется на Концептуальную, судебную, законодательную, исполнительную; по другому — на представительную и непредставительную («назначательную»). В демократическом Обществе последней вообще нет места. Это означает, что принимать содержательные решения может только представительная власть, а назначаемый сверху чиновник этого права законодательно лишается и выполняет чисто регистрационные, организационные и исполнительные функции. Впрочем, не всякая представительная власть: исполнительная ветвь государства обязана быть представительной, тем не менее, она должна быть лишена права законодательной инициативы.

К тому же следует приучить и народ, и действующие ныне «власти» вместо этого вздорного и общественно-вредного слова употреблять термин «система управления». Государство — одна из подсистем Общества. А именно, подсистема управления.

В английском языке различают Doctor of Law и Doctor of Jurisprudence. Первый — законник, знаток действующего законодательства. Второй — правовед, знаток философских основ права, системно-логического базиса права, методологии построения права, критериев оценки правозаконности законодательной деятельности государства. И неслучайно английское право подразделяется на два концентратора: общее право и право справедливости.

**Главное в построении учебника «Правоведение» — показать чёткую восходящую цепочку: закон — право — правоведение.**

То есть, разумеется, реально эта цепочка вырастает в обратном порядке: правоведение даёт общие принципы права; право доводит их до правовой доктрины, из которой растут конкретные законы. Не соответствующий Праву закон априори юридически ничтожен. Это известно даже нашему убогому Конституционному суду.

Право и законодательство (совокупность законов) — две различных системы. В автократии они могут вообще не пересекаться. В разных демократиях они пересекаются с разной степенью перекрытия. Полностью совпадать они в принципе не могут. (Иначе не

было бы смысла говорить о двух системах). Закон принимается государством. Точнее, конкретными (часто вполне случайными) людьми, и отражает интересы этих людей (или представляемых ими кланов и группировок). Право порождается Обществом (наукой от имени Общества). Общество в системной иерархии выше государства: государство — подсистема управления Общества. Поэтому Право — выше закона. Следовательно, закон должен быть следствием права. А вовсе не его источником, как пишут сегодняшние учебники.

*Право — подсистема Культуры, непосредственно формирующая и контролирующая деятельность человека как социально ответственной и законопослушной личности и определяющая все запреты и ограничения, налагаемые Обществом на своё государство.*

Право представляет собой систему взаимосвязанных идей, максим, норм и принципов, определяющих формирование законов. Оно содержится в научных трудах, исторически накопленных Обществом в процессе его развития. Поэтому у «позитивистов» нет никаких оснований признавать правом лишь то, что содержится в «освященных» государством сиюминутных поделках: Общество вечно, государство — сиюминутно.

*Закон — следствие Права. Не вытекающий из Права закон — противоправный закон; он признаётся неправозаконным, а, следовательно, ничтожным.*

Для ясности и удобства чтения приведём здесь же дефиниции входящих в настоящие определения терминов.

*Культура — исторически изменяющаяся системообразующая функциональная подсистема Общества, формирующая человека как социально активную и законопослушную личность и удовлетворяющая его духовные потребности — путём производства, хранения, распределения и потребления духовных ценностей.*

Культура — системный базис права. Какова Культура, таково и Право. При советской власти считалось, что человека формирует КПСС. На самом деле это функция Культуры. Конечно, в формировании человека участвуют и другие подсистемы Общества — «материальное» (правильнее — вещественное) производство, подсистема общественных отношений, система физического воспроизводства населения; однако для них это — попутная и случайная задача. Для Культуры же формирование человека — единственная цель и оправдание её существования.

*Духовная ценность — результат творчества, поднимающий человечество или личность на новый уровень понимания мироустройства или эмоционального восприятия себя самого и своего окружения.*

Понимание мироустройства — это мировоззрение; восприятие себя и окружения — мироощущение.

*Творчеством признаётся процесс, в результате которого из известных реалий создаётся нечто объективно новое или обнаруживаются ранее не известные реалии.*

Сформулируем наше отношение к Обществу и государству.

*Общество — система, организующая на некоторой территории разумных и целенаправленных особей в интересах обеспечения их жизнедеятельности, направленной на достижение определённых духовных, экологических и вещественных идеалов.*

*Государство — подсистема Общества, координирующая функционирование всех остальных подсистем и организующая все необходимые Обществу знаковые и вещественные потоки, — методами и в жёстких рамках правил, установленных Обществом.*

Правовое государство — законодательно признающее себя и гражданина равнозначными субъектами Права. **Гражданское Общество — высшая стадия развития демократического общества, при которой правовое государство полностью**

**подчинено Обществу, и интересы государства состоят в защите интересов личности и Общества.**

Забегая вперёд, приведём здесь же дефиницию понятия «система»

*Система — совокупность элементов, объединённых в цельную структуру прямыми и обратными связями, определяющими свойства системы, выходящие за рамки простой суммы свойств составляющих её элементов.*

Чтобы понять сущность объекта, нужно представить его в виде системы: определить, в ряду каких систем он находится, из каких собственных подсистем он сам состоит, элементом какой метасистемы он является.

Итак. ***Предметом курса «Правоведение» является система Права — не локального права, не системы законодательства, а источника законов, системы их взаимосвязей и обоснований, критического анализа «текущих» законов и методов их приближения к нормам Права, типовых ошибок законотворчества и правотворчества, общих недоработок и теоретических проблем Права.***

Частные нормы права должны изучаться в отдельных «текущих» локальных курсах.

Таким образом, в известном смысле **правоведение и есть Общая теория Права.**

Из этого и будем исходить.

Попутно проанализируем сегодняшнюю ситуацию в преподавании того предмета, который ныне незаконно именуется правоведением.

До недавнего времени учебников правоведения были считанные варианты. Однако к 2004 году прорезалось сразу множество новых учебников (Агапов Р.Д. и др.; М.Н.Марченко, Е.М. Дерябин; Комаров С.А. и др.; Тихомиров Ю.А.; Мухачёв Р.Т.; Гойман Г.И. и др.; «Учебно-опорный конспект лекций» Соколова А.Н.; «Учебное пособие для вузов» Айтмана Т.О. и многие другие). Рассматривать их все нет ни возможности, ни надобности. Мы остановимся на наиболее типичных.

В практике преподавания встречаются два типа учебников: «Право» и «Правоведение». Примером первой группы может служить учебник под ред. Н.А. Тепловой и М.В. Малинкович [1]. Министерством общего и специального образования РФ он «рекомендован студентам высших учебных заведений, обучающимся по экономическим специальностям». То есть не юристам. Логика такова: дать общее представление о праве (точнее, о законодательстве), не вдаваясь в концепции, сложности и противоречия. Основной объём учебника посвящён гражданскому праву. Однако пропорции явно нарушены: слишком много внимания уделено разного рода договорам, слишком мало — проблеме юридического лица и собственности. При этом не делается ни малейшей попытки соотнести область правотворения и область законодательства; вскользь упоминается, что закон — основной источник права. (Как далее будет доказано, это досадное заблуждение).

Видимо, именно такого эффекта от подобного курса добивается сегодняшняя высшая школа: студент должен усвоить примитивизированные представления о нормах, создаваемых государством, не вдаваясь ни в какие обоснования сложившихся структур, в явные противоречия законодательства, и отучаясь всё больше — по мере продвижения по курсу — от каких-либо сомнений и привычки задавать «неудобные» вопросы.

При этом государство упускает из виду, что система, лишённая отрицательных обратных связей, идёт вразнос. До полного физического уничтожения управляемой системы. Сегодняшняя Россия пошла именно по этому катастрофическому пути. Остановить её — главная задача Правоведения.

Для второй группы характерен «учебник для вузов» (так написано на титульном листе — без указания, что он рекомендован Минобразования) «Правоведение» под редакцией Б.И. Пугинского [2]. На обороте титула указано: «Учебник предназначен для неюридических вузов. Содержание учебника полностью соответствует действующей учебной программе курса «Правоведение». Следовательно, из анализа учебника мы можем судить о содержании этой самой программы. Которая явно неудовлетворительна. Прежде всего, в том, что подменяет разговор о проблемах Права разжижением действующего

законодательства. Во-вторых, перекосом в пользу малосущественных (конкретных) деталей взамен анализа принципиальных проблем Права и Правоведения.

Быть может, можно использовать такой учебник в средней школе. Но назвать его следовало бы так: «Краткий обзор действующего российского законодательства».

К правоведению этот «учебник» не имеет никакого отношения. Это не более чем разжиженный справочник по сегодняшнему российскому законодательству. В нем даже нет определения предмета. Более того, слово «правоведение» красуется только на обложке и далее ни разу (!) не встречается в сей «замечательной» книге. Её первый раздел «Общие положения о государстве и праве» сразу же ставит студента в привычно-замороженную позицию безотрывности права от государства. Как будто на свете нет никаких иных подходов к теории права, кроме позитивистского. (Который, по моему глубокому убеждению, принципиально ошибочен).

А далее вообще — раздел II напрочь уводит от теории права, занимаясь только описанием сегодняшнего (не только в принципе преходящего, но и весьма плохо обоснованного) российского законодательства. Хотя он и назван «Основы государственно-правового устройства России», но не содержит никаких общетеоретических обоснований нашей правовой системы, а просто комментирует известные (не всегда юридически корректные) статьи ныне действующей Конституции РФ. (См. «Замечания к КРФ»).

Третий раздел посвящен якобы «Правовому регулированию гражданских правоотношений». Но если вы начнёте его читать, немедленно убедитесь, что это — всего лишь пересказ ныне действующего Гражданского Кодекса РФ. Авторы учебника настолько завязли в непонимании принципиальной разницы между правом и законом, что абсолютно не в состоянии показать студенту, где кончается убогая сиюминутная краткоживущая практика законодательства и начинается непреходящая наука о Праве. Интересно, слышали ли они (не студенты, а авторы учебника), что бывают неправовые законы — даже по решению нашего малоэффективного Конституционного суда?

На этом фоне полным нонсенсом выглядит четвёртый раздел — «Правовое обеспечение частных интересов граждан». Разве предыдущий раздел посвящён чему-то другому? Зато пятый раздел способен умилить внимательного читателя. Он присутствует в «учебнике» дважды: с одним и тем же названием («Правовое регулирование других видов отношений»), но с абсолютно разным содержанием. Которое, однако, как и всегда, сводится к пересказу действующего законодательства. И хотелось бы всё же спросить авторов: что это такое — в логико-системном и юридическом плане: — «другие виды отношений»?

Рассмотренные учебники плохи уже тем, что принципиально неспособны соответствовать единственной собственной задаче — описать текущую ситуацию в законодательстве. Ибо последнее меняется быстро и непредсказуемо, завися от конкретных лиц, разными путями дорвавшихся до власти в стране. Мы исходим из того, что правоведение не должно стремиться описать стохастически сложившиеся законы. Добавим — не всегда правозаконные. И быстротекущие: сегодня одна Дума, завтра — другая. Да и не от Думы сегодня у нас зависят законы, а от теневой организации, в которую попадают далеко не лучшие и плохо предсказуемые люди.

Правоведение как наука о наиболее общих и наиболее важных проблемах Права, основываясь на принципах системоанализа, информатиологии и философии, не должно заниматься локальными конкретными нормами, кои являются объектами гражданского права и других конкретных областей права. Главные объекты Правоведения:

- Рациональная структура права
- Гражданское общество
- Самоуправление
- Правовое государство
- Экологические корни права
- Рациональная конституция

- Интеллектуальное право
- Проблема дефиниции собственности
- Проблема дефиниции юридического лица
- Культура как системный базис права
- Проблемы информациологического права.

Правовед должен видеть недостатки действующего законодательства. Поэтому ниже дан анализ наиболее важных конкретных законов. Начиная с конституции.

Разбиение на множество отдельных веточек для Права неизбежно — как и для Науки в целом. Но нельзя признать рациональным (и даже просто разумным) разбиение в таком виде, в каком оно стохастически сложилось, пока юристы варились в собственном соку, — то есть бессистемно. И ещё более важно понимание, что знание основных принципов освобождает от необходимости знания необозримого поля фактов. И неизмеримо эффективнее. Не зря небезызвестный сыщик Шерлок Холмс так любил метод дедукции.

Здесь полезно вспомнить о такой притче. Каждый учёный стремится докопаться до сути. Он ограничивает область поиска (выбирает собственный пяточок в бескрайнем поле науки) и начинает интенсивно копать. Вот он кандидат. Вот доктор. Затем — членкор; наконец — академик. Дальше копать бессмысленно. Он поднимает то, чем рыл, кверху и видит: над ним — небо с овчинку и никаких коммуникаций с соседними колодцами. Кому-то надо остаться на поверхности. Более того — оторваться от неё повыше. И увидеть общий рисунок устьев персональных колодцев. И убедиться, что большую их часть давно пора засыпать. И начинать копать совсем в другом месте.

Понятно, что такое представление с пеной на губах оспаривается всем кланом «государственных» отечественных юристов, получивших искажённое одностороннее «чисто» юридическое образование, пишущих бездарные замороченные учебники и обучающих студентов привычному «отстою». С этим пора решительно кончать.

Понятно, что это непросто. Не только из-за своекорыстного сопротивления законников. И потому тоже, что подготовить правоведа на три порядка сложнее, чем юриста-законника. Как сказал классик, можно всю жизнь проработать кочегаром, не имея представления о теплотехнике. Законник не слышал даже такого имени — Гёдель. Его (не Гёделя, а законника) не учили всерьёз формальной логике, он понятия не имеет о принципах системного анализа, он плохо ориентируется в стилистике русского языка, он, как правило, даже не слышал слово «информациология». Потому всё, выходящее из-под его пера, бессистемно, нелогично, стилистически и даже грамматически безграмотно. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать налоговый кодекс или действующую конституцию РФ. Самое же главное общественное зло от законника — его упёртое непонимание принципиальной подчинённости государства Обществу (а именно — Гражданскому Обществу), а закона (порождаемого государством) — Праву, создаваемому Наукой от имени Общества.

Изменить это положение можно единственным способом: отобрав у государства монополию на классификацию научных кадров и на принудительное внедрение «государственных образовательных стандартов». Понятно, что любое государство «правовых» чиновников себе всегда подготовит. Но в интересах Общества (а потому и государства!) всегда иметь высокообразованную и эффективную оппозицию, выполняющую функции отрицательной обратной связи. Или — «адвоката дьявола», если некоторым так понятнее. Обществу необходима подлинная интеллигенция. Которая «с молоком матери» впитает смысл и важность противодействия любой власти. Даже самой порядочной. Интеллигенция, которая не побежит с априорной поддержкой к властям предрежущим. И с протянутой к ним же рукой (в надежде, что «чего-нибудь дадут» — как сказал некогда мною весьма уважаемый известный артист).

Полагаю, сказанного достаточно, чтобы признать актуальной эту истину: знание основ правоведения необходимо культурному человеку даже более, чем знание науковедения. Понятно, что знание конкретных законов, изданных «текущим» государством, так же менее важно для формирования интеллигента, как и детальное знание конкретных частных

законов природы. Важны общие идеи, концепции и парадигмы. Важно знание методологии, позволяющей самому находить новые знания и эффективно освобождаться от засилья устаревших. К студенту надо относиться как к фиалу, в котором надо возжечь огонь разума, а не как к мешку, который надо поплотнее набить быстро устаревающими конкретными частными знаниями.

Понятно, что реализация этой программы невозможна без системы самодостаточных, ни в чём не зависящих от государства — надгосударственных — учебных заведений. Которые будут выше «даруемого» государством права выдачи «госдиплома» и не будут обеспокоены возможностью спасения от призыва в армию.

Роль правоведения в жизни общества чрезвычайно велика. Особенно сегодня.

Сегодня мы живём в быстроизменяющемся мире. Не успели оправиться от дискредитации коммунистической идеологии, как пришлось тут же осознать, что безыдейное поведение — ещё хуже. Человек, не обременяющий себя никакой идеологией, с удручающей неизбежностью начинает вести себя по-свински. И это в лучшем случае. В худшем — преступно. Попутно выяснилось, что древняя панацея, раньше успешно ограждавшая общество от полной деградации — религия, — сегодня уже совсем плохо справляется со своими задачами. Если не сказать больше. Выяснилось также и то, что маргинально-капиталистическая идеология ничего хорошего честному труженику не сулит: «в люди» прежде всего выбиваются циники, полукриминальные плутократы (они же «олигархи») и откровенные мошенники. Умные люди оказались «за скобками», процветают «сообразительные». И это — во всём Море, хотя России здесь, безусловно, принадлежит одно из первых мест.

Возникает самый вечный из всех вечных вопросов: «Кто виноват?» (и «Что делать?») — то есть, где корни зла и как выходить из ситуации окончательной деградации Общества.

Есть серьёзные основания полагать, что ответы на эти вопросы не лежат в области экономики: передовые учёные-экономисты (например, депутат Госдумы С.Ю. Глазьев, Ю.М. Осипов из МГУ) уже осознали, что современное экономическое учение потерпело полное фиаско. Сегодня вопрос стоит так: либо человечество найдёт принципиально новый способ управления Обществом, либо — продолжая губительное для Земли «развитие» под руководством «экономистов» — погибнет под развалинами родной планеты. Оставив после себя только пепел — и в вещественном, и в идейном плане.

Общеизвестно (хотя сегодня и далеко не всеми осознано), что политика — это концентрированная экономика. Со всеми, следовательно, её, экономики, глупостями, подлостями и безобразиями (ВВП, частная собственность на невозполнимые природные ресурсы, ссудный процент). К тому же, как громогласно возвещают сами политики, она, политика — дело грязное и малоидейное: «искусство возможного», так сказать. Так что было бы совершенно ненаучным искать ответы на вечные вопросы в политике.

О роли религии уже сказано. Трудно ждать от неё, занятой сегодня межконфессиональными распрями, и хуже того — напрямую порождающей разнообразные «джихады» одних «правоверных» против других, — разумных, конструктивных, ответов на «проклятые вопросы».

Остаётся единственный конструктивный механизм — право.

Правда, как показали проведённые автором исследования, и в этой области с идеологией далеко не всё в порядке. Устарели общепринятые представления о роли и месте государства в обществе. Есть весьма обоснованные возражения против широко распространённых трактовок понятия «гражданское общество». Немало возражений против духа и буквы ныне действующей конституции РФ. Вплоть до того, что она содержит, как показывает тщательный анализ, прямые системно-логические и даже лексико-грамматические ошибки. Массу всяческих возражений вызывают и гражданский, и налоговый кодексы. Прямые грамматические и системные ошибки содержит уголовный кодекс.

Но хуже всего обстоят дела в области интеллектуальной собственности. И самый вредный для общества подход оформился здесь в целенаправленное и настойчивое



отрицание необходимости, и даже возможности правовой защиты идеи — как основы всяческой идеологии и как основного объекта не только интеллектуальной собственности, но и собственности вообще.

Сегодня как никогда становятся актуальными философские основы права — мировоззренческое объяснение смысла и предназначения права, его обоснования с позиций системного анализа, исходя из сути человеческого бытия, из концепции существующей в этом бытии системы ценностей. Необходимо, наконец, осознать, что право есть одна из подсистем Культуры, что самодовлеющее изучение лоббирующих чьи-то интересы законов под видом правоведения не имеет ни теоретического, ни практического смысла; что «внеэкологичное» Право не имеет права на существование. Так же, как и внеэкологичная экономика. К сожалению, современная культурология отягощена непримиримыми внутренними противоречиями и не способна предложить какого-либо работоспособного алгоритма установления статуса Культуры как метасистемы, как системного базиса права. В силу этого сегодня столь актуальны любые «нетрадиционные» исследования в этой области.

Со времён Римской империи цивилистика признавалась основой правовой системы: *«...именно гражданские законы — это те главные факторы, с помощью которых идеалы свободы, требования демократической и правовой культуры фактически реализуются в повседневной жизни граждан, и тем самым с юридической стороны обеспечивается реальное формирование современного свободного гражданского общества»* (С.С. Алексеев, [3]). Сегодня весьма актуально и другое наблюдение вышеупомянутого автора: римское право отнюдь не представляет собой результат сглаженной и усреднённой коллективной проработки (что столь характерно для сегодняшнего российского правоведения), римское право — плод сильного и оригинального индивидуального ума. Этот подход и сегодня весьма актуален. И по сути, как показала и отечественная, и мировая практика, не имеет альтернативы. Истина не «лежит посередине» — там может существовать только ещё одна проблема. Так реализуется один из основных принципов системного анализа.

Сегодня интеллектуальное право молчаливо (то есть без каких-либо серьёзных обсуждений и диспутов) признаётся подсистемой (частью) гражданского права. Серьёзных обоснований этого подхода нет ни у кого. Обсуждение этой проблемы — вплоть до признания интеллектуального права самостоятельной ветвью системы права — весьма актуально. Особенно на фоне возникших сегодня тенденций выделить в самостоятельную ветвь банковское право и признать необходимой для общества четвёртую ветвь государственного механизма — банковскую власть. Исходя из сказанного, весьма актуальны исследования в сфере оптимизации структуры и функций четвёртой власти. Тем более, что по многим серьёзным соображениям, ею должна стать вовсе не банковская, а **Концептуальная** власть. (Быть ли ей четвёртой, или, напротив того, первой — также весьма актуальная проблема для серьёзного исследования).

В рамках системы интеллектуального права сегодня правомерно признать наиболее актуальной проблему правовой защиты идеи.

Весьма актуальной является и задача применения интегральной мощи аппарата системного анализа ко всей сложной системе вышеописанных взаимосвязанных проблем.

Таким образом, наша первая цель заключается в критическом анализе системно-логической ситуации, сложившейся на сегодня в сфере теории Права в целом и интеллектуального права в частности — с учётом всех его сложных системообразующих пересечений и взаимосвязей, — с последующей разработкой принципиально новой — системной — концепции правовой защиты интеллектуальной собственности.

Исходя из широкоизвестной теоремы Гёделя о неполноте, решить поставленную задачу в рамках отдельного рукава Права невозможно: её решение надо искать в анализе и переработке основ общей системы Права. Естественным образом на этом пути возникает ряд новых аспектов основополагающих проблем: соотношения Права и закона, государства

и Общества, «центральной власти» и «местного» самоуправления. Самостоятельную проблему представляют правоотношения в сфере Интернета и компьютерных технологий.

Попутно преследуется дополнительная цель: разработать семиотические основы для построения новой, внутренне непротиворечивой системы взаимосвязанных дефиниций, необходимой для создания нового основополагающего юридического тезауруса.

## **2. Философия права. Методы исследования**

Обычно авторы трудов и учебников по теории права не отвергают огромной роли философии в обосновании принципов и основополагающих аксиом права. И им трудно было бы вести себя иначе: «Право есть вообще свобода как идея» — это сказал не кто-нибудь, а один из наиболее знаменитых философов (Гегель).

Философское осмысление права — древняя традиция: Аристотель, Фома Аквинский, Гуго Гроций, Иммануил Кант немало усилий предприняли для разработки философии права. В их работах философский подход к осмыслению права состоит в попытке постигнуть основополагающую идею права, игнорируя все национальные и исторические различия во внешних формах его проявления.

Философские основания органически входят в содержание любой фундаментальной науки, определяют её мировоззренческое и методологическое значение. Очень часто от исходной философской идеи зависит степень обоснованности разработанной гипотезы или концепции. Это полностью справедливо и для теории права.

И современные теоретики-правоведы не оставляют без внимания философию права. Известный поборник идеи создания юридических систем, способных возвыситься над властью, С.С. Алексеев, в качестве основы выдвигает **идею правозаконности**: «Начиная с эпохи Просвещения философская мысль по вопросам права, развиваясь и оттачиваясь, в своём едином движении неизменно склонялась к одному — к тому, что основой права, его стержнем и предназначением является свобода. И не просто свобода, не свобода вообще, не абстрактно понимаемая идея свободы, а...реальная, в живой юридической плоти *свобода отдельного автономного человека*. ...Именно соединение передовой философской мысли о сути человеческого бытия и реального развития политико-правовой действительности в последние два столетия даёт надёжное основание для вывода о том, что суммой философско-правовых идей (концепцией) о праве в жизни людей, отвечающей требованиям нынешней стадии человеческой цивилизации, должна стать *ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПРАВА — ФИЛОСОФИЯ ПРАВОЗАКОННОСТИ*».

При этом С.С. Алексеев подчёркивает два важных момента. «Гуманистическое» — это не затёртый эпитет, к месту и не к месту употребляемый массовыми коммуникациями и разномыслными политтехнологами, а термин в своём изначальном, точном значении: характеристика явлений в жизни Общества, сконцентрированных вокруг человека, человеческих ценностей и интересов. «Правозаконность» означает строжайшее, неукоснительное претворение в жизнь **не любых и всяких норм, а начал гуманистического права**, прежде всего основных, неотъемлемых прав человека. В отличие от этого термин «законность» характеризует лишь одно из имманентных свойств любого права, его общеобязательность — категоричность, непременность соблюдения, претворения в жизнь действующих юридических норм — неважно каких, в том числе как «революционных», так и самых что ни есть реакционных».

Такая философия права представляется более совершенной и более обоснованной, чем примитивная (хотя и реализованная сегодня во многих «развитых» странах) философия, основанная на якобы изначальном «праве государства».

В современном Гражданском Обществе *философия правозаконности* должна господствовать и править. Эта философия призвана определять приоритет прав человека по отношению к правам государства. Она должна определять содержание, смысл и направления деятельности всех судебных, законодательных, исполнительных (включая

правоохранительные) органов по всем вопросам, на которые так или иначе распространяются права человека.

Изначальность прав человека — важнейший философский принцип, его можно рассматривать как индикатор для проверки существа той или иной правовой системы. Если утверждается, что «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (статья 2 Конституции РФ), можно усомниться в системно-логической и философской квалифицированности авторов подобного утверждения. Либо — признаться в лицемерности и фарисействе подобной правовой системы. Поскольку права человека возникают просто вследствие факта его рождения, и являются таким образом априорными, не зависящими от воли какого-либо органа управления; эти права просто *не входят в компетенцию государства*. Для государства, важно одно: ни под каким предлогом оно **не вправе нарушать права человека**. И оно, государство, изначально лишено права решать эту проблему по-своему: признавать — не признавать, защищать — не защищать, считать это своей обязанностью или нет. Государство, не признающее такой максимы, конечно, может существовать (какое-то время — пока Общество будет его терпеть), но в соответствии с законами философии, системного анализа и формальной логики подобное государство не может именоваться демократическим. Что бы ни говорила официозная пропаганда о сути такого государства, оно всё равно будет оставаться какой-либо разновидностью деспотии (диктатуры).

Предвидя возможное возражение, что де всё-таки лучше зафиксировать в конституции обязанность государства соблюдать права человека, ответим следующим образом. Записать такую обязанность государства можно, но не в такой форме (которая приведена выше). Эта формулировка вовсе не исключает такой трактовки: права человека дарованы ему по доброй воле государства. А вот это как раз и есть нарушение основного философского принципа изначальноности прав человека: *права человека выше прав государства*. Первые даны человеку «от Бога», вторые — **дарованы** государству Обществом. Поэтому для выражения демократической сущности государства в конституции следует писать так: **«В демократическом обществе государство полностью подчинено Обществу, а права и интересы человека выше прав и интересов государства»**.

Обратим внимание на ещё одну, по-видимому, привычную, а потому практически никем не замечаемую, несообразность. Все авторы теоретических работ по праву единодушны в одном: основной принцип философии права — признание самоценности и высшей роли во всех правовых построениях понятия **справедливость**. Но те же самые авторы молчаливо (а подчас и напротив того — весьма велеречиво) соглашались с положением, при котором автор некоего «вещественного» решения вправе жить на доходы от использования его решения другими людьми, в то время как автор интеллектуального решения (идеи) не только на практике, но и теоретически такого права лишён. При этом используются аргументы, которые, по нашему мнению, ошибочны как с философской точки зрения, так и с позиций системного анализа. Например, часто используемая псевдодихотомия «материальный — идеальный». Любое «идеальное» решение — а оно «по определению» всегда является *информационным* решением, — столь же материально, как и любое *вещественное* решение. Проще говоря, столь распространённая аргументация против законодательной защиты **идеи** происходит от элементарного непонимания идей современной философии. Согласно этим новым основам философии, мир материален в том смысле, что он объективен и не является продуктом нашего воображения. *Поэтому всё сущее — материально*.

Разумеется, для вульгарного материализма, утверждавшего: материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях (известное ленинское определение), также нет никаких оснований. Во-первых, совершенно не важно, «дана» ли материя нам или кому-либо иному: не будучи «дана» никому, она продолжает оставаться материей. Остаётся материя материей и в том случае, если «дана» не нам. Что касается наших ощущений, то и здесь В.И. Ленин не был прав: нам даны только результаты нашего

взаимодействия со всей остальной Вселенной. Ибо наше присутствие во Вселенной как-то деформирует её метрику. Как именно — этого мы пока не знаем (хотя гравитационное взаимодействие вполне могли бы уже учитывать), но сей — количественный, а не качественный, — факт никакого значения не имеет для принципиальных философских определений.

Возвращаясь к философским основам права, вынуждены отметить, что сегодня укрепилась абсолютно несправедливая идея ненужности правой защиты идеи. Почему-то считается, что она, идея, изначально принадлежит всем. По моему убеждению, всем должны принадлежать невосполнимые природные ресурсы. Идея же — она не «от Бога», она — плод индивидуального труда. Не говоря уж о том, что идея вещи значительно важнее для Общества, чем сама вещь. Обладая идеей вещи, последнюю всегда можно воспроизвести; обратное, как правило, невыполнимо: миллиарды людей обладают и пользуются вещами, абсолютно не осознавая идеи этих вещей.

Мне представляется вполне убедительным приведённое доказательство возможности правовой защиты идеи — *как её дефиниции*.

\*

Перейдём к методологии исследований.

В современной правовой литературе принято выделять следующие основные методологические принципы: всесторонность исследования, комплексность исследования, применение диалектического метода; применение методов: восхождения от конкретного к абстрактному (и обратно), исторического, формально-юридического, метода сравнительного правоведения, правового моделирования, конкретно-социологического метода.

Между прочими методами, как бы между прочим, упоминается и *системный метод*. Это выглядит знаковым явлением: у нас изначально имеет место непонимание сути системного анализа, области применения *системного подхода*. Хотя их упоминание стало как бы правилом хорошего тона.

Неверно также и утверждение, что метод исследования якобы непосредственно вытекает из предмета исследования. Подобное утверждение напрямую нарушает один из основных законов формальной логики — закон достаточного основания. (Который сам нередко понимается превратно: исключительно как необходимость обосновывать каждое положение в доказательстве). В правильном понимании закон достаточного основания утверждает, что **метод доказательства должен быть обоснован независимо от доказываемого тезиса** (следовательно, независимо от предмета исследования).

Удивляет, что ни в одном из рассмотренных источников (см. перечень использованной литературы) я не встретил однозначного и чёткого указания на абсолютную необходимость использования во всех юридических исследованиях всех без исключения законов **формальной логики**. Нелогичный юридический язык — это, как минимум, странно. Тем не менее сегодняшняя ситуация именно такова.

Нигде не было замечено также упоминание о необходимости неукоснительного использования в теории и практике юриспруденции основного вывода известной теоремы Гёделя о неполноте.

\*

Автор по дополнительной специализации — системноаналитик. Поэтому имеются все основания применить для настоящего учебника в качестве основной методологии именно системноанализ — в оптимальном сочетании с классическим аппаратом формальной логики.

В своё время автор приложил немало усилий к развитию теории системноанализа и созданию конкретных методов оценки эффективности и экономичности систем. Результаты этих многолетних исследований излагаются в следующей главе.

### **3. Системоанализ. Системный подход как наиболее**

## **обобщённая методология современной науки**

Системоанализ (иногда называемый также системным анализом или анализом сложных систем) — область науки, изучающая методологические принципы, концепции, практические методы для обоснования решений по сложным экономико-политическим, социальным, военным, научно-техническим, экологическим и правовым проблемам в условиях неопределённости, обусловленной наличием факторов, не поддающихся однозначной количественной оценке.

В процессе проведения системоанализа формируются варианты решения, на основе которых можно сделать окончательный выбор оптимального решения — по определённым, заранее установленным критериям.

Системоанализ включает и строгие математические методы, и неформализуемые практические приёмы, основанные на интуиции и широкой эрудиции авторитетных специалистов. Процедуры системоанализа ориентированы на выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы, выявление масштабов неопределённости по каждому из вариантов. В итоге выполняется сопоставление всех вариантов по определённым критериям *эффективности* и *экономичности*.

Несколько важных предварительных замечаний. Нередко при решении какой-либо вроде бы понятной исследователю проблемы формируется тем не менее неверная постановка задачи. Случается, что принятый критерий эффективности не отражает существа задачи. Ввиду важности вопроса изложим суть концептуальной новеллы, рассказанной полвека назад основоположниками Исследования Операций Кимбеллом и Морзом.

В годы второй мировой войны американцы и англичане несли большие потери от немецкой авиации в морских судах. Эти «морские транспорты» (как их именовали американцы) везли из США в Великобританию (а иногда и в СССР — в рамках так называемого «лэндлиза») вооружение, продовольствие и разнообразное оборудование. Для защиты от немецких подводных лодок транспорты объединялись в большие «конвои» и защищались кораблями охранения. Подводные лодки преодолеть этот заслон из кораблей охранения не могли. (Подлодка значительно тихходней и менее манёвренна сравнительно с противолодочным кораблём). Но с самолётом ситуация диаметрально противоположна: немецкие пикировщики легко прорывались сквозь бреши в частоте кораблей охранения и безнаказанно топили беззащитные транспорты. Увеличить численность кораблей охранения — чтобы их зоны противовоздушной обороны надёжно перекрывали друг друга — было весьма затруднительно по многим причинам.

И тогда возникло, как казалось, естественное решение: поставить зенитные пушки непосредственно на каждый транспорт — пусть он защищает себя сам. Что и было сделано.

Однако корабль имеет определённое водоизмещение — значит, из-за установки на него пушек надо что-то с него снять. Например, часть полезной нагрузки. А также и экипажа, поскольку оружейную прислугу надо кормить и надо её разместить в кубриках. В итоге увеличивается время простоя транспорта в порту под погрузкой - выгрузкой. Когда всё это было осознано американскими адмиралами, пришла мысль оценить эффективность тех самых зенитных пушек. Адмиралитет сформулировал задачу так: определить, сколько немецких самолётов сбито этими «транспортными» пушками. Исследование дало несколько неожиданный результат: абсолютный ноль. И эти зенитки чуть было не начали снимать с кораблей.

Однако в недрах адмиралтейства нашлись-таки продвинутые молодые люди (впоследствии заложившие основы системоанализа), указавшие адмиралам на их принципиальную ошибку: эффективность таких пушек вовсе не в сбитии вражеских самолётов. Она — в предохранении транспорта от потопления вражеским самолётом. То есть считать нужно не сбитые самолёты, а потопленные транспорты. Когда провели соответствующее расследование, убедились: все сто процентов потопленных транспортов были без пушек.

И тогда всё стало понятным (что нередко случается, когда задача решена): если по летчику стреляют, он действует строго в рамках инструкции по бомбометанию: на заданной высоте, с заданной дистанции; и, разумеется, — мимо. А вот когда пилот не чувствует никакого противодействия, он наглеет: выходит прямо на транспорт и без опаски пикирует на него. Результат в этом случае ясен. Был ещё и такой метод: «топмачтовое бомбометание». Топ — это вершина мачты. На незащищённый корабль бомбардировщик выходит на малой высоте и над топом выполняет «горку». При этом он на мгновение как бы зависает над кораблём. Тут достаточно открыть бомбодержатели — и бомба падает точно в дымовую трубу.

Отсюда один из главных принципов системоанализа: прежде всего нужно чётко уяснить существо решаемой задачи. В сегодняшней российской юриспруденции наиболее часты сбои именно в этом компоненте.

В семидесятые годы прошлого века идея применения системного подхода к сложным проблемам управления стала очень популярной. Юриспруденция же — безусловно, именно система управления. Со всеми присущими системе атрибутами: прямыми и обратными связями, критериями эффективности и экономичности и проч. Редактор переводной книги «Системы и руководство» ([4], Р. Джонсон и др.) писал: «Потребность в литературе, где излагались бы основы построения систем различного типа, в настоящее время весьма велика. Авторы выбрали в качестве такой основы системный подход. Весь мир, всё, что мы видим вокруг, состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих систем. Эта точка зрения глубоко диалектична и исключительно плодотворна. Руководитель, овладевший системным подходом, по-новому «видит» предприятие и производственные процессы, он обладает фундаментом для научной организации всего процесса руководства и применения специальных методов.

Управление, основывающееся только на опыте и интуиции руководителя, становится всё чаще неэффективным. Для решения некоторых проблем руководства уже имеются хорошо разработанные методы. Они содержатся в таких дисциплинах, как системотехника, теория вероятностей и теория массового обслуживания, вычислительная техника, цифровое и аналоговое моделирование, линейное и динамическое программирование, анализ сетей (с вытекающими из него методами сетевого планирования), инженерная психология и т.д. Одно лишь это перечисление научных дисциплин, которые могут быть полезны руководителю в его практической деятельности, приводит к вопросу: как весь этот разнородный материал связать воедино? Какова та платформа, опираясь на которую руководитель сможет эффективно применять эти методы? Такую платформу и даёт системный подход. Его использование позволяет принять во внимание множество факторов самого различного характера, выделить из них те, которые оказывают на объект наибольшее влияние с точки зрения имеющихся общесистемных целей и критериев, и найти пути и методы эффективного воздействия на них. Системный подход основан на применении ряда основных понятий и положений, среди которых в первую очередь следует выделить понятия системы, иерархии, потоков материалов, информации и энергии».

Добавим: всё сказанное полностью справедливо и для управления Обществом с помощью государства. Следовательно — и для общей теории Права.

Повторим ещё одно чрезвычайно важное замечание: необходимо отучить и Общество, и подчинённое ему государство от привычного термина «власть», решительно заменив его термином «подсистема управления». Из этого проистекут не только весьма глубокие теоретические новации, но и остро потребные сегодня коренные практические выводы.

Как было отмечено выше, самой первой по времени дисциплиной этого междисциплинарного класса было Исследование Операций. Сложившись в годы второй мировой войны как инструмент оптимизации военных операций, в последующие годы ИО стало с большим успехом применяться и для решения чисто гражданских задач.

Из рассмотренных примеров можно сделать один общий вывод: задача Исследования Операций формулируется как *оптимизация поведения уже созданной системы*. (На корректном научном языке это называется так: *поиск оптимального закона управления для заданной системы*).

В те же годы сложилась и теоретическая часть системотехники — общая теория систем. Её предмет — упорядоченная теоретическая концепция, предназначенная для описания общих взаимосвязей реального мира. Если система не задана, то есть исследователь вправе менять её параметры (оптимизировать структуру и функции системы) — это и есть проблема Системотехники. Иначе говоря, Системотехника исследует принципы и методы проектирования сложных систем, предназначенных для достижения вполне определённых, заданных, целей. Поскольку очевидно, что оптимальный закон управления для оптимальной системы существенно отличается от оптимального закона для неоптимальной системы, при определении наилучшего облика системы под заданные цели, одновременно оптимизируются и закон управления, и параметры системы.

В общей задаче Системоанализа цели проектируемой системы тоже оптимизируются — вкупе с параметрами и законом управления. Здесь ситуация такова: известны только ограниченные ресурсы. Какие задачи сможет решать некая наилучшая в пределах заданных ресурсных ограничений система — это и есть вопрос, на который надо получить ответ. Вопреки злопахотствам всё же существующих и ныне зоиллов системоанализа, он даёт вразумительные ответы там, где любые другие подходы вообще не могут дать никаких содержательных ответов.

Таким образом, вполне резонно представлять Системоанализ как метасистему, включающую в себя как свои части (свои подсистемы) Исследование Операций, Системотехнику и Теорию Эффективности систем. *Системоанализ — одна из наиболее обобщённых междисциплинарных наук, исследующая принципы и методы оптимизации систем.* Поскольку в Мире нет абсолютно ничего, что не являлось бы системой, эта наука должна рассматриваться как общая метасистема науки, как её философско-логический базис.

Следует заметить, что термин «системоанализ» может вполне закономерно использоваться и в локальном значении: как название процесса анализа и оптимизации некой конкретной системы.

Как известно, наука не кончается дефинициями. Но без них нет никакой науки. Поэтому начнём с разработанных нами дефиниций. Некоторые из них уже приводились в разделе 1. Но, как известно, повторение — мать учения.

*Система — это совокупность элементов, объединённых для достижения общих целей в цельную структуру прямыми и обратными связями, определяющими наличие свойств системы, выходящих за рамки простой суммы свойств составляющих её элементов.*

Пояснение. Свойства воды не равны сумме свойств составляющих его элементов — водорода и кислорода. Свойства Общества не равны сумме свойств составляющих его личностей.

Элементы системы — её *подсистемы*. Сама система — элемент *надсистемы* (метасистемы). Системы подразделяются на «материальные» (вещественные) и абстрактные. Последними занимается наука *семиотика*.

Вещественные системы по одному основанию могут быть подразделены на живые и неорганические. По другому основанию можно различать статичные и динамичные (развивающиеся) системы; последние могут быть детерминированными или стохастическими (вероятностными). По характеру взаимоотношений со средой системы подразделяются на замкнутые (обменивающиеся со средой только энергией) и открытые — ведущие постоянный обмен со средой не только энергией, но и веществом. Человек, Человечество, Экономика — открытые системы. Многие открытые системы способны поддерживать *гомеостазис* — постоянство своих внутренних параметров в условиях изменяющейся среды. Этим свойством обладают *самоорганизующиеся системы*. Человек, Человечество относятся к *целеустремлённым системам*.

Структурная схема общей декомпозиции систем представлена на рис. 1. (с. 19).

Сформулируем основной принцип системоанализа:

*Чтобы понять сущность объекта, нужно представить его в виде системы: найти, в ряду каких систем он находится, из каких подсистем он сам состоит, элементом какой метасистемы он является.*

В ходе системоанализа строятся обобщённые модели, отображающие факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые способны реализоваться в процессе осуществления выработанного решения. На модели проверяются: *эффективность* и *экономичность* каждого из альтернативных вариантов решения, их чувствительность к различным нежелательным внешним воздействиям, возможность решения различных

сопутствующих задач. Выбор наилучшего варианта выполняется на основе *сравнительной экономико-эффективностной оценки альтернативных решений*.

В отечественной науке (в юридической — особенно) накопилось много устоявшихся заблуждений в этой области. Велика путаница в теории и практике экономики: здесь синкретично смешиваются *эффект* и *эффективность*, *эффективность* и *экономичность*; применяется ошибочный

д р о б н ы й критерий — в виде показателя эффективности (а нередко и просто эффекта), отнесённого к единице затрат; ошибочно ставятся и решаются *поликритериальные задачи*. Все эти ошибки присутствуют и в практике применения патентного права.

Системоанализ позволяет по-новому подойти ко всем вышеперечисленным проблемам и сформировать внутренне непротиворечивую систему основополагающих понятий (**тезаурус**), необходимую для ответа на самые общие и самые важные вопросы о роли и месте Права в целом и в частности интеллектуального права в демократическом *информационно-сотовом Гражданском Обществе*.

В литературе нередко наряду с термином «системоанализ» применяется и термин «системный подход». Причём эти термины нередко синкретично смешиваются.

В рамках разработанной нами теории, каждый из этих терминов имеет самостоятельный смысл и своё особое место в системе современной науки. Адекватное определение термина «системоанализ» — как *особой самостоятельной области науки (самостоятельной ветви научного знания)* — уже сформулировано нами выше.

**Системный подход** — общенаучный методологический принцип, основанный на представлении исследуемого объекта в виде системы; он ориентирован на раскрытие целостности объекта, учёт всех его внутренних и внешних взаимосвязей, комплексный охват всех факторов, влияющих на искомое решение.

Системный подход способствует адекватной формулировке проблем и правильной постановке задач, а также выработке эффективной методики их решения.

*Системный подход служит основной методологией системоанализа.*

Ещё раз подчеркнём важность *идеи* о правильной постановке задачи.

В этом со мной согласны все ведущие системоаналитики. В частности, знаменитый Э. Квейд в его основополагающей книге «Анализ сложных систем» [5] пишет: «Опасность этого этапа заключается в том, что могут не уделить достаточного времени на выявление подлинного содержания проблемы. Как я уже говорил, основная трудность анализа систем часто заключается в том, чтобы уяснить, *что надо делать, а не в том, чтобы определить, как это надо сделать*.

Вместо того чтобы следовать по пути, который, по мнению или указанию заказчика, считается лучшим, хороший специалист по анализу систем будет стремиться найти новый подход к решению задачи. Здесь очень опасен соблазн «развернуть работу», не обдумав как следует своей задачи.

Уже первые работы по анализу систем, в которых принял участие автор, показали, как важно думать об общих проблемах и задавать дополнительные вопросы». (Последнее требование, заметим кстати, непосредственно вытекает из уже упоминавшейся теоремы Гёделя).

Элементы системного подхода встречаются уже в античной философии. Но только в XX веке он начинает занимать ведущее место в научном познании. В ряде областей возникают проблемы организации и функционирования сложных объектов, техника всё больше превращается в технику сложных систем. В управлении Обществом вместо господствовавших прежде локальных отраслевых задач и принципов начинают играть ведущую роль крупные комплексные проблемы, требующие взаимоувязывания политических, правовых, экономических, социальных, экологических, психологических аспектов общественного устройства.

Изменение типа научных и практических задач сопровождается появлением общенаучных и специальных концепций, реализующих основные идеи системного подхода: появление глобальных проблем и глобальных систем в учении В.И. Вернадского о



биосфере и ноосфере; выделение особого класса систем — информационно-управляющих — появление кибернетики, информатики, информациологии. Не будет преувеличением утверждение, что сегодня любая частная наука становится действительно наукой не столько благодаря использованию математики, сколько благодаря широкому применению системного подхода. Всё сказанное безусловно относится к юриспруденции.

В философском плане системный подход — конкретизация основных принципов диалектики.

В системном анализе реализуются главные принципы системного подхода: задача формируется и решается комплексно — с учётом всех существенных внешних условий; любой объект представляется в виде системы — иерархически организованной многоуровневой структуры, включающей элементы (подсистемы), объединённые прямыми и обратными связями — для достижения общей для всех элементов конечной цели.

Ещё в 60-е годы, в период работы в Центральном Институте Министерства Обороны автор сформулировал собственные определения *основных принципов системного анализа*:

1. Любой объект может быть представлен в виде системы — совокупности элементов, объединённых ради достижения неких единых, общих для всех элементов конечных целей в единую структуру с помощью прямых и обратных связей.  
По прямым связям командные сигналы от подсистемы управления поступают ко всем остальным элементам системы, по обратным связям от элементов системы подаются в подсистему управления сообщения о результатах выполнения ранее поступивших команд. Устойчивая система обязательно располагает **отрицательными** обратными связями — такими, которые парируют воздействие на систему в целом поступающих от подсистемы управления команд, «срезая» избыточную часть управляющего сигнала. Система, не имеющая отрицательных обратных связей, а культивирующая только положительные — то есть усиливающие действие управляющего сигнала, — такая деформированная система с железной необходимостью идёт вразнос. Об этом следует помнить всем, кто связан с формированием теории государства и права.
2. Любая система состоит из подсистем и сама является элементом (подсистемой) системы более высокого порядка (метасистемы).
3. Декомпозиция (разбиение системы на подсистемы) основывается на понимании существа задачи, для решения которой предназначена рассматриваемая система; при этом обязательно учитываются все *системообразующие* подсистемы — такие, без которых рассматриваемая система не может существовать.
4. Свойства системы не равны сумме свойств её элементов.
5. Цели подсистем не могут противоречить цели системы.

6. Любая система с одной стороны характеризуется эффективностью, и совершенно с другой — экономичностью. Эффективность в общем случае в деньгах не выражается. В деньгах выражается экономичность системы.

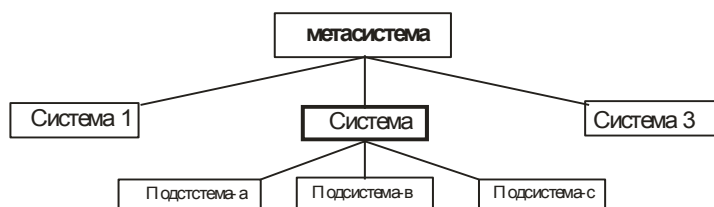


Рис.1

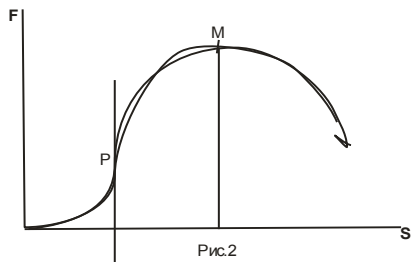


Рис.2

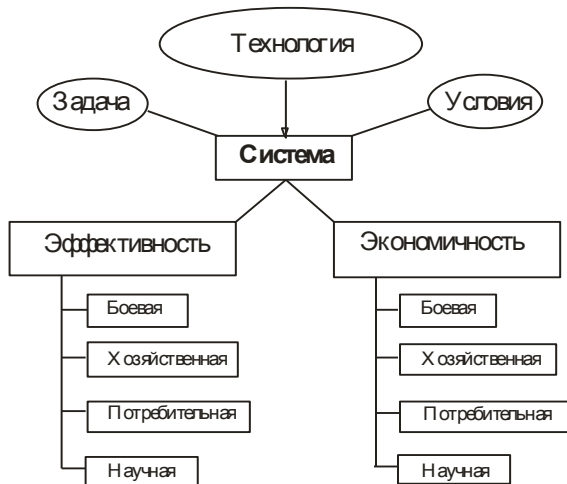


Рис.3



Рис.5

7. Критерии эффективности подсистем должны быть компонентами или частными производными критерия эффективности метасистемы.

8. Системный подход — наиболее обобщенная методология всей современной науки.

Число верхних и нижних уровней системной иерархии, которые подлежат исследованию при создании системы, определяется решаемой системой задачей и конкретными целями исследования.

В практике проектирования систем к наиболее тяжёлым (тем не менее, широко распространённым) ошибкам принадлежат синкретичное смешение эффективности и экономичности системы, неверное представление о взаимосвязи эффективности и эффекта, применение дробных критериев и суперпозиций в поликритериальных задачах.

Каждая система характеризуется с одной стороны эффективностью, и совершенно с другой — экономичностью. Для ясности и чёткости понимания начнём с примера.

Можно заколачивать гвозди фотоаппаратом. Можно, но не нужно: сие действие крайне неэкономично. (Фотоаппарат стоит столько, что всей жизни не хватит, чтобы окупить его стоимость путём заколачивания гвоздей). Весьма экономично заколачивать гвозди булыжником. Но весьма неэффективно. Эффективнее всего заколачивать гвозди молотком. Ибо он в максимальной степени приспособлен к решению именно этой задачи. Следовательно,

*Эффективность есть показатель степени приспособленности системы к решению определённой задачи в определённой ситуации.*

Экономичность системы тем выше, чем ниже (при заданной эффективности) суммарные затраты на создание и эксплуатацию системы.

Суммарные затраты определяются формулой:

$$S_c = S_{\text{разр}} + S_{\text{пр}} + S_{\text{э}} + A \dots \dots \dots (1)$$

Где:

$S_{\text{разр}} = S_{\text{ф}} + S_{\text{п}} + S_{\text{окр}} + S_{\text{и}}$  — затраты на разработку

$S_{\text{ф}}$  — затраты на фундаментальные исследования

$S_{\text{п}}$  — затраты на прикладные исследования

$S_{\text{окр}}$  — затраты на опытно-конструкторские работы

$S_{\text{и}}$  — затраты на испытания

$S_{\text{пр}}$  — затраты на производство

$S_{\text{э}}$  — затраты на эксплуатацию

$A$  — «штрафная функция».

Фундаментальные исследования — это поиск новых природных закономерностей.

Прикладные исследования — поиск областей практического применения найденных закономерностей.

ОКР — поиск оптимальных конструктивных решений по применению найденных закономерностей в определённых областях человеческой деятельности.

Испытания — это комплексное тестирование опытных образцов создаваемой системы.

$A$  — это выраженная в деньгах плата за нерешение побочных для системы задач и за возможные потери при использовании системы (в людях, ресурсах, экологии, престиже).

Очевидно, что экономичность системы есть величина, обратная суммарным затратам.

Типовая зависимость эффективности системы от её экономичности показана на рис. 2. (Для удобства представления этой функции за аргумент приняты суммарные затраты). Очевидно, что существует определённое оптимальное значение суммарных затрат.

Удивительное непонимание приведённых соображений характерно для большинства современных российских «корифеев» от экономики. Более того, большинство экономистов не осознаёт принципиальную разницу между эффективностью и экономичностью (см. рис. 3); при этом для них абсолютно непонятно, что в общем случае эффективность никакого отношения к деньгам не имеет, а привычное для них словосочетание «экономическая эффективность» — просто привычная несообразность. Повторим: любая система с одной стороны характеризуется эффективностью — показателем степени приспособленности системы к решению определённой задачи (что в деньгах не выражается), и совершенно с другой стороны — экономичностью, то есть той ценой, которую Общество вынуждено платить (в виде суммарных затрат) за решение данной задачи именно этой системой.

Причём подлинная суть (соответственно, название) как эффективности, так и экономичности полностью определяются назначением системы: если система решает боевую задачу, она обладает боевой эффективностью и боевой же экономичностью. Если задача народно-хозяйственная, то эффективность и экономичность — народно-хозяйственные. Как уже сказано, «экономическая эффективность» — либо просто глупость, либо под словом «экономическая» следует понимать «народно-хозяйственная».

Недопустимость дробных критериев типа  $dF/dS$  можно проиллюстрировать не только математически, но и на литературном, так сказать, примере.

Л.Н. Толстому принадлежит утверждение, что человек подобен дроби: в числителе то, что он представляет собой на самом деле, а в знаменателе — то, что он о себе воображает. При всём кажущемся изяществе этой формулы Льва Николаевича, она принципиально ошибочна и идейно вредна. Если воспользоваться ею для реальной оценки людей, мы можем получить совершенно idiotический результат. Надо сравнить двух человек. Один — крупный учёный, второй — вор-рецидивист, душегуб и убеждённый мерзавец. В числителе у этого мерзавца, естественно, должна стоять большая отрицательная величина. Но этот мерзавец не вовсе идиот: понимает, что приносит Обществу не пользу, а вред; однако величину этого вреда существенно занижает (ну, подумаешь, порешил десяток человек — что у нас людей что ли мало?). Таким образом, общая оценка этого мерзавца «по Толстому» будет положительной (минус на минус даёт

плюс) и больше единицы (числитель толстовской дроби больше знаменателя). Не правда ли, странноватый результат?

Но с учёным получается ещё хуже. Он, конечно, уже облагодетельствовал человечество и в числителе у него огромная положительная величина. Огромная, но конечная. А вот в знаменателе — актуальная бесконечность. Ну, самомнение у него такое! И что же получается по-Толстому: интегральная оценка учёного равна нулю! Не проще ли признать, что Лев Николаевич был не столь силен в логике, сколь в литературе? (Впрочем, для меня и второе не вполне очевидно).

Так что вернёмся к строгой аргументации. Если воспользоваться приведённой на рис. 2 общей зависимостью критерия эффективности (**F**) от показателя экономичности (**S**), можно сделать весьма обоснованные и чёткие выводы.

Сегодня экономисты страшно любят критерии типа «прибыль на рубль затрат». Это и есть тот самый дробный критерий, против которого мы решительно возражаем. Действительно, в числителе здесь некое подобие критерия эффективности (прибыль; хотя, как уже сказано, эффективность в деньгах не выражается, но экономисты этого всё ещё не знают...), а в знаменателе — чёткий критерий экономичности (затраты). Где же этот дробный критерий достигает максимума? Разумеется, в точке «Р» — там, где угол наклона касательной к кривой достигает максимума. (Эту точку называют точкой перегиба: и левее неё, и правее — углы касательных меньше, чем в этой точке).

А где следовало бы находиться? Ну, конечно же в точке «М» — там, где достигает максимума абсолютное значение критерия эффективности. Соответствующие затраты и являются оптимальными.

Вывод: уж если что-либо сравнивать, то либо по знаменателям — *при равных числителях* (конечно, всегда приятнее иметь дело с менее амбициозным субъектом — но лишь при одинаковой его значимости для Общества, что и у его самонадеянного оппонента), либо сравнивать по числителям при равных знаменателях. А сравнение по соотношению этих показателей либо бессмысленно (при попарном равенстве обоих показателей), либо даёт вышеописанный идиотский результат.

Правильный выбор критерия эффективности определяет саму возможность получения разумного решения: при неадекватном критерии (не отражающем существа решаемой системой задачи) результат ваших усилий всегда будет отрицательным. (Вспомните хотя бы «пушки на кораблях»).

Нетрудно доказать (что и выполнено в соответствующих работах автора), что такой «основополагающий» критерий эффективности экономики (строго говоря, народного хозяйства), о котором небезызвестный Самуэльсен даже сказал, что он де «самое ценное из всего придуманного человечеством», как ВВП (*валовой внутренний продукт*), на самом деле — очень плохой критерий: лукавый, некритичный и нерепрезентативный. Он лукав уже потому, что включает и необоснованное удешевление численности и денежного содержания охраны-обслуги всех действующих и отставных президентов, и сведение г-ном Касьяновым лесов в какой-либо российской области, и проедание бюджетных средств многочисленными новыми нуворишами и чиновниками. Он **абсолютно аморален**: показывает якобы рост экономики, в то время как на деле имеет место повышение спроса на оружие, наркотики и проституцию. Он растёт, когда происходят различные природные, техногенные и социальные катаклизмы. Его можно считать тремя разными способами: по затратам, по доходам и по расходам. Даже в США результаты расчётов сильно расходятся. О России и говорить нечего. Он нечувствителен к уровню жизни конкретных страт Общества: изображает нечто, подобное «средней температуре по больнице» (средней между моргом и палатой тифозников). И это называть критерием!

Автором показано: критичным, репрезентативным и релевантным критерием эффективности такой системы, как экономика, следует признать *среднюю продолжительность жизни населения*. Если удастся найти его адекватное математическое выражение, связывающее аналитически (или хотя бы корреляционно) со всеми аргументами, характеризующими эффективность всех подсистем Общества,

зависящих от результатов функционирования экономики, и, в свою очередь, влияющих на *условия жизни человека*, — задача оценки эффективности экономики будет решена в наиболее строгой и полной постановке. Именно в этом направлении сегодня и следовало бы ориентировать основные усилия экономической науки.

**Правовая наука должна разработать законодательное обеспечение этой идейной перестройки.**

Необходимо добавить: средняя продолжительность жизни характеризует не только оставшееся время, которое пенсионер может просидеть перед телевизором. (Для сегодняшней России это вопрос праздный: это время для россиян меньше нуля — средний россиянин просто не доживает до пенсии). Однако средняя продолжительность жизни характеризует средний **производительный потенциал поколения**. Элементарные расчёты свидетельствуют: по этому показателю мы проигрываем Японии примерно в шесть раз (у них средняя продолжительность — 85 лет, у нас — 57). Что и объясняет экономическую разницу между нами — учитывая, что в среднем от режима «всасывания» к режиму отдачи человек способен перейти к 50-ти годам.

Удивительно, что многие популярные ныне критерии ни у кого не вызывают сомнения — несмотря на то, что явно не выдерживают критики с позиций системного анализа. Например, один из главных критериев в бывшем ведомстве Аксёненко: тонно-километры. Ведь достаточно было бы просто подумать о том, что переместить тысячетонный монолит на один километр — далеко не то же самое, что перевезти одну тонну груза на тысячу километров. Или пресловутые «человеко-часы». Разве бригада землекопов в 24 человека за один час решит задачу, на которую один учёный потратил сутки? И нелепо возражать на это, что де надо же учитывать каждый раз «реальную ситуацию»: одним из мощнейших методов доказательства в логике всегда был знаменитый *Reductio ad absurdum* — сведение к абсурду. Поставив систему (в том числе и метод) в крайнюю ситуацию, вы сразу обнаруживаете все её органические недостатки — принципиальные, неустранимые и опасные недостатки. Применение этой методологии в юриспруденции может дать немалые положительные результаты.

Один из важнейших принципов системного анализа — комплексный подход, то есть совместное решение взаимосвязанных задач.

Следовательно, не без оснований подход Толстого мы предлагаем заменить системным подходом.

Делается это следующим образом. Первое: устанавливается конкретный вид критерия эффективности, соответствующего поставленной перед системой задаче. Второе: определяется потребная численная величина этого критерия. Третье: для каждой из конкурирующих систем определяется потребная численность группировки, обеспечивающей решение поставленной задачи с требуемой эффективностью. Четвёртое: рассчитываются суммарные затраты на создание и эксплуатацию каждой группировки (неприменно, с учётом штрафной функции). Пятое: наилучшей признаётся система, обеспечивающая решение главной задачи, а также и полного набора всех попутных (вспомогательных) задач, — с наименьшими суммарными затратами.

Естественно, те системы, которые не способны к решению вспомогательных задач, дополняются вспомогательными системами. Что, естественно, увеличивает для них потребные суммарные затраты (и делает в итоге сопоставление конкурирующих систем действительно абсолютно корректным).

Вышеописанная постановка проблемы обычно именуется «прямой». Она удобна при выборе наилучшей системы из числа предложенных («задача военпреда»). В том случае, когда априори заданы выделенные ресурсы (ассигнования), удобнее «обратная» постановка: сначала создаются (рассчитываются) «располагаемые» группировки для каждой из конкурирующих систем (то есть такие группировки, которые точно — ни больше, ни меньше — «укладываются в смету»). Наилучший способ реализации выделенных ассигнований — тот, который обеспечивает наибольшую эффективность по главной задаче — при приемлемых показателях эффективности по всем вспомогательным задачам.

Между прямой и обратной постановками есть одно существенное различие. В первом случае (при прямой задаче) решение является абсолютным и не требует никаких дополнительных доказательств. Во втором случае придётся доказать, что достигаемый уровень эффективности достаточен. Но и не слишком избыточен.

Для ещё большей ясности по всей проблематике системного анализа, вернёмся к нашему примеру с забиванием гвоздей. Наиболее эффективную систему по этой задаче — молоток — можно выполнить из дорогостоящих материалов (вплоть до украшения рукояти рубинами и изумрудами — поступали же так с оружием). Если при этом не менять никаких рабочих параметров молотка — длины и диаметра рукояти, формы, веса и жёсткости бойка — эффективность молотка не изменится. А его экономичность резко упадёт.

В принципе можно использовать молоток и по новому назначению. Например, как пресс-папье. (Этот случай даже предусмотрен в действующем законодательстве и охраняется по патентному праву). А можно — как оружие. При этом можно увеличить эффективность такого оружия, заточив боёк на конус. (Или расплющив и заточив по всей ширине лезвия. Как у топора). Но по забиванию гвоздей эффективность «боевого» молотка упадёт.

Вывод: эффективность не бывает «вообще» — это характеристика приспособленности системы к решению определённой конкретной задачи. Второй вывод: эффективность и экономичность — две принципиально различных характеристики. Поэтому и не следует употреблять оборот «экономическая эффективность». Будем надеяться, что наши славные экономисты когда-нибудь это всё-таки осознают.

Надо также осознать и принципиальную разницу между эффективностью и эффектом. Эффективность — имманентная характеристика самой системы, непосредственно вытекающая из её параметров. (При оптимальных параметрах системы обеспечивается её максимальная эффективность). Эффект — результат применения системы в некоторых внешних условиях, сложившихся случайным образом. Причём в принципе эти условия содержат как детерминированные, так и стохастические компоненты. И даже неопределённые — которые невозможно описать и при помощи законов распределения. Эффективность однозначна: она — функция системы и задачи. Эффектов же всегда неограниченно много: технический, экономический, экологический, политический и т. д.

Эффект, естественно, зависит от эффективности. Однако из этого вовсе не вытекает, что эффективность можно определить через эффект: это запрещено из-за влияния на эффект неопределённых внешних условий. И недаром в логике известно «правило необратимости силлогизма»: если сегодня у меня нет денег, потому что я потерял свой кошелёк, то отсутствие денег вовсе не означает, что я потерял кошелёк, — может, у меня его никогда и не было.

К сожалению, синкретичное неразделение эффекта и эффективности, попытки определять эффективность через эффект — всё это у нас широко распространено. Проиллюстрируем сказанное одним давним, но весьма показательным примером. В середине 80-х Госкомизобретений издал «Инструкцию по расчёту единовременного вознаграждения за новые технические решения и изобретения». (Хотя, к слову, *по определению*, изобретение и есть новое техническое решение. Ещё один пример «знания» логики). Первая глава той инструкции называлась: «Определение величины эффективности». Первый параграф этой главы назван: «Годовой экономический эффект». Для авторов инструкции что эффективность, что эффект — нечто неразличимое. И, видимо, одинаково малопонятное, ибо далее идёт конкретный пример: электробритва. По мнению авторов инструкции, эффективность электробритвы определяется «годовым экономическим эффектом от её продажи».

Ну, а если я изобрёл новую бритву, но никому её не продаю — бреюсь сам...неужто она, эта новая бритва, из-за этого начисто лишена эффективности?

Разумеется, нет. Эффективность электробритвы в чистоте бритья: её можно выразить либо частотой побритий, необходимой для сохранения заданной гладкости кожи, либо

высотой остаточного волоса (чистотой бритья). А «годовой эффект» и «продажа» — всё это здесь абсолютно не при чём.

Припомним ещё один замечательный пример. В романе О. Генри «Короли и капуста» двое симпатичных аферистов, попав в захолустный океанический городок, населённый босоногими туземцами, решили подзаработать на продаже башмаков. Однако туземцы покупать башмаки не пожелали. Они привыкли обходиться вовсе без башмаков. Но и аферисты были не промах: в одну из безлунных ночей по всем тропинкам разбросали несколько центнеров колючих репейников. Наутро туземцы осадили обувной магазин.

Спрашивается, пока туземцы башмаков не покупали, они (башмаки) были лишены эффективности? Ну, конечно же нет! Эффективность башмака возникает на листе ватмана (строго говоря, ещё раньше — *в идее*): это толщина подошвы, прочность и пылевлагонепроницаемость его швов — всё то, что определяет степень защиты (на сей раз, не юридической, а физической) ноги от пыли, грязи, воды и колючек.

Ещё раз напомним: *эффективность необходимо связать с параметрами системы*. Иначе систему нельзя оптимизировать.

С продажей же связан только эффект: пока туземцы не имели нужды в башмаках, — не было желаемого экономического эффекта; пошла продажа — эффект появился.

Очень важно осознать следующее: эффективность имеет место и при полном отсутствии эффекта. Эффективность (боевая, разумеется) атомной бомбы огромна. Хотя эффекта — слава Богу! — пока-что не предвидится никакого. И что должны бы были сделать правоохранительные органы с тем упрямым конструктором, который не пожелал бы научиться определять возможности бомбы расчётным путём — через её параметры, — а фанатично настаивал бы на её применении в порядке эксперимента над каким-либо городом — неважно, своим или чужим?

*Вывод: определять эффективность через эффект — грубейшая системно-логическая ошибка.*

Перейдём к поликритериальным задачам. Сегодня в подобных случаях у нас в ходу всяческие «взвешенные» критерии — в виде суперпозиций или (что ещё хуже) дробей (дробных соотношений критериев типа «прибыль на рубль затрат»). Такой подход изначально порочен. Не только потому, что в ответе даёт физически бессмысленную величину (например, «полтора землекопа» или «25 человеко-часов»). Ещё и потому, что с помощью пресловутых «взвешивающих коэффициентов» (назначаемых, как правило, без каких-либо убедительных обоснований) можно провести оптимизацию системы всего лишь по одному критерию (скажем, из десяти), нагло утверждая при этом, что решена десятикритериальная задача.

О недопустимости дробных критериев всё необходимое уже сказано выше. Добавим лишь, что в условиях поликритериальной задачи недопустимость дробного подхода удешевляется.

Рассмотрим наглядный пример: выбор личного оружия (пистолета или револьвера). Не станем углубляться в детали (например, по поводу сравнительных преимуществ и недостатков барабанного и магазинного оружия), условимся только, что нам доступна любая из существующих сегодня моделей (систем) личного оружия. (Именно такую задачу решал в своё время небезызвестный Джеймс Бонд).

Пистолет характеризуется множеством параметров: размеры, вес, внешний вид (иногда и это важно: никелированное оружие блестит, воронёное — нет), удобством (скоростью) перезарядки, количеством патронов в магазине, наличием или отсутствием курка, скорострельностью, наличием или отсутствием автоматического огня, точностью стрельбы (величиной среднеквадратичного отклонения точки попадания от точки прицеливания), дальностью прицельной стрельбы, калибром, пробивной способностью, наличием (или отсутствием) шокового эффекта, громкостью хлопка при выстреле. Можно было бы назвать ещё немало важных параметров, но и названных вполне достаточно, чтобы понять главное.

Современный подход состоит в том, чтобы построить некий составной критерий, включающий суперпозиции (суммы) и отношения локальных критериев (т.е. характеристик).

Ну, и что мы получим, просуммировав длину пистолета и его вес, вычтя из этого среднее отклонение и прибавив дальность прицельной стрельбы? Разумеется, ничего кроме глупости. И результат не станет вразумительнее, если далее мы поделим первую суперпозицию на другую (включающую, к примеру, число патронов, калибр и цвет покрытия).

Вывод однозначен: так поступать категорически нельзя.

Корректные действия при решении поликритериальной задачи таковы: провести *ранжировку* критериев, чётко представляя конечную цель функционирования системы. Затем провести оптимизацию системы (как описано ранее) по наиболее важному критерию, учтя все остальные критерии в виде ограничений (вес не более **В**, запас патронов не менее **П**, время перезарядки не более **Т** и т. д.).

Очевидно, что последовательность параметров при ранжировке зависит от решаемой задачи и данных будущего владельца: даме для самообороны более всего подойдет один пистолет (то есть для этого случая одни показатели окажутся превалирующими, например, размеры и вес, а дальность — какую бог пошлёт), полицейскому нужен совсем иной пистолет (главное здесь — останавливающий эффект), военному подойдёт третий, киллеру (извините за упоминание) — четвёртый.

На третьем шаге снова проводится оптимизация системы. Но уже по критерию второго ранга. А перворанговый критерий «загоняется» в общую «компанию» ограничений.

Затем оптимизация проводится для третьего по важности критерия. И так далее — пока не будут рассмотрены все критерии, вошедшие в ранжировку.

В итоге перед исследователем откроется полная картина: сколько будет потеряно в эффективности по первому критерию, если позаботиться и о приличном значении второго критерия; сколько потеряете в первом и втором критериях, озаботившись величиной третьего. И так далее. Окончательное решение имеет вид компромисса: наилучшее сочетание основных критериев при приличных значениях всех остальных. При этом, естественно, необходимо чётко представлять, чем вы готовы поступиться в эффективности по задачам более высокого ранга ради того чтобы обеспечить одновременно и достаточно высокую эффективность по всем вспомогательным задачам.

Только такой подход даёт вместо завуалированной чепухи достаточно обоснованное оптимальное решение поликритериальной задачи.

Теперь рассмотрим важные выводы, которые методология системного анализа должна сделать из ранее упомянутой теоремы Гёделя. Она относится к тем проблемам, которые в математике пользуются достаточной известностью, но традиционно признаются слишком сложными для включения в обязательное обучение: обычай относит такие проблемы к занятиям факультативным, дополнительным, специальным и т. п.

Несмотря на то, что многие математики (и нематематики) слышали об этой теореме, мало кто из них может объяснить, в чём именно состоит утверждение теоремы Гёделя. И тем более — как она доказывается. Но результат столь важен, а причины, вызывающие неустранимую неполноту, столь просты, что теорема Гёделя могла бы изучаться на самых младших курсах.

Поскольку автор не является профессиональным математиком (и вряд ли кто-либо из них окажется читателем настоящей работы), нет нужды приводить здесь строгое математическое доказательство. К тому же оно уже было выполнено неоднократно — не только самим Гёделем, но и многими другими математиками (см., например, [6]). Поэтому вполне обоснованно — оставить доказательство знаменитой теоремы на совести математиков, но воспользоваться её плодами в интересах развития методологии системного анализа. А в конечном счёте — в интересах разработки общей теории Права и теории Интеллектуального права.

Переводя математическую формулировку теоремы на элементарный русский язык, суть теоремы Гёделя можно изложить следующим образом: в любой системе («множестве», как говорят математики) могут содержаться элементы («утверждения»), в отношении которых принципиально невозможно провести ни доказательство их истинности, ни доказательство



их ложности. Однако в более полной системе — частью которой является рассматриваемая система — такие доказательства существуют. (Естественно, и в этой более полной системе существуют собственные элементы, сущность которых не может быть однозначно установлена в рамках самой этой системы. Но можно определить суть этих элементов в рамках метасистемы, охватывающей «более полную» систему. И так далее.).

Вообще говоря, если бы в своё время (в начале позапрошлого века) Гёдель не доказал бы своей теоремы, это всё равно сделал бы кто-нибудь из сегодняшних системоаналитиков. Сама логика системоанализа неизбежно ведёт к этому. (Еще раз посмотрите, к примеру, на седьмой принцип системоанализа на 19-ой странице: его вполне можно истолковать как одно из следствий теоремы Гёделя).

Самое же важное следствие из теоремы Гёделя — применительно к поставленным в настоящей работе задачам — состоит в том, что проблемы оптимизации интеллектуального права принципиально не могут быть решены исключительно в рамках самой этой частной отрасли права. *Они могут найти решение только в рамках общей теории права.* Иначе говоря, для оптимизации «права интеллектуальной собственности» необходимо оптимизировать его метасистему. Таковой является не гражданское право, а общая «теория государства и права». (Кавычки служат лишним напоминанием о том, что давно назрела необходимость как минимум поменять эти термины местами). Что касается самой общей теории Права, то она тоже не может быть оптимизирована «внутри самой себя» — для решения этой проблемы необходимо найти и оптимизировать метасистему Права.

Что касается практической реализации идеи нового подхода к построению системы правовой защиты интеллектуальной собственности, то, исходя из вышесформулированных следствий теоремы Гёделя, придётся признать справедливой следующую максиму: *построение оптимальной системы правовой защиты интеллектуальной собственности в современной России возможно только в ходе оптимизации всего государственного механизма.*

## **4. Рациональная структура Права**

Пришла пора воспользоваться методикой, описанной в предыдущем разделе. Определим рациональную декомпозицию системы Право.

Взгляды на сущность права сегодня неоднозначны. В своё время у нас главенствовало представление о праве (оформленное родоначальниками марксизма) как воле господствующего в политике и экономике страны класса. Многие «присяжные» российские правоведы и сегодня фактически придерживаются всё тех же представлений. Во всяком случае, когда настаивают на понятии о праве как порождении государства. При этом они упорно настаивают на том, что неотъемлемая характеристика права — его «обеспеченность возможностью государственного принуждения» [7]. На наш взгляд, эти правоведы делают всё ту же системно-логическую ошибку — смешивают право с законом. Ведь на самом деле государство настаивает на исполнении закона, а вовсе не нормы права. Иначе к чему бы наши нескончаемые стенания, что кому-то вечно не хватает каких-то законов? Пресловутая «воля государства» — законы. Очень часто, как показывает наша убогая жизнь, — противоправные.

Правда, и сторонники этих обскурантистских взглядов иногда чувствуют свою неправоту и нечёткость: в том же труде «7» написано: «содержание права создаётся обществом, форма права — государством». Конечно, в общем-то это вздор. Как известно, форма неотрывна от содержания и всегда ему соответствует. Физически невозможно создать содержание чего-либо, не облекая это в какую-то определённую форму. А изменение содержания немедленно требует изменения формы. И уж конечно полная бессмыслица — представление о какой-то «чистой» форме, лишённой всякого содержания. Однако сама эта неуклюжая и системно-логически порочная сентенция говорит о многом. Прежде всего,

о неуверенности адептов исключительности «позитивного» права в собственной белизне и пушистости.

На самом же деле, конечно, Обществом (наукой от имени Общества) создаётся право, а государством — законы. Все остальные кривотолки — «от лукавого».

Единственное, в чём они безусловно правы, — в том, что «Право представляет собой сложное системное образование» [7]. Однако принципы декомпозиции системы **право** (т.е. подразделения этой системы на её элементы — её подсистемы) весьма расплывчаты и совершенно бессистемны.

Во-первых, право «...делят на три элемента, на естественное, позитивное и субъективное право». Во избежание кривотолков, не будем интерпретировать эти позиции сами, а просто продолжим цитату всё из того же источника («7»): «Первый элемент — естественное право, состоящее из социально-правовых притязаний, содержание которых обусловлено природой человека и общества. Важнейшая часть естественного права — права человека, или, иначе говоря, возможности, которые общество и государство способны обеспечить каждому гражданину». Здесь явная логическая несообразность: мало ли что государство *способно* обеспечить. Если неспособно — это плохое *государство*. Какое же отношение это имеет к **правам человека**, — которые изначально (принадлежат человеку «по факту его рождения»), государством необсуждаемы, и ни от каких решений государства не зависят? Ведь **право** это вовсе не то, чего оно хочет или что оно может, — право это что государство *обязано*. А закон — это всего лишь мнение государства по поводу того, как должен вести себя его же собственный чиновник, и чем он должен руководствоваться в решении проблем, возникающих между гражданами — строго в соответствии с нормами права. Поэтому делить право на вышеупомянутые три якобы подсистемы бессмысленно.

Вторая несообразность: если права человека всё же — часть естественного права, то где остальные его части? Короче, данное определение, мягко говоря, некорректно. И практически бесполезно. (Оно — типичный образец бессистемного «юридического» словоблудия).

Тем не менее, продолжим цитирование: «Второй элемент — позитивное право. Это законодательство и другие источники юридических норм, в которых получают официальное государственное признание социально-правовые притязания граждан, организаций, социальных групп». Здесь всё та же логико-системная путаница. То, что авторы «7» называют позитивным правом, на деле является законами, принимаемыми каким-то государством. Как известно, многие подобные законы могут быть неправовыми. Закон есть следствие права — и уже поэтому не может быть источником права. Источники права — правовое самосознание народа; философские максимы, взгляды концепции и теории; парадигмы и теории правовой науки. Реально существуют две системы: право и законы. Они могут вообще не совпадать (например, в тоталитарном или авторитарном обществе), могут как-то пересекаться (в либерально-демократическом обществе) и могут в значительной степени пересекаться (в Гражданском Обществе с правовым государством). Но полностью совпадать — как два разных объекта — они не могут по определению: тогда не было бы никакого резона вообще говорить о разных объектах. И любому здравомыслящему человеку априори понятно, что право является «лекалом» для закона, а не наоборот. Надеюсь, вы слышали про конституционный суд? Таким образом, и эта часть определения структуры права во взглядах сегодняшнего официального правоведения совершенно неадекватна.

Закончим цитату из «7»: «Третий элемент — субъективное право, т.е. индивидуальные возможности, возникающие на основе норм позитивного права и удовлетворяющие интересы и потребности его обладателя». Здесь мы видим к тому же и плохое знание норм русского языка. К чему относится это «его» — если к «возможностям», то они другого рода (надо было хотя бы писать «их»); если же авторы «7» имели в виду «субъективное право», то это, конечно же, вздорное словосочетание — «обладатель права» (в лучшем случае, — «прав»). Если отнести «его» к «потребностям» — получим совершеннейший вздор:

обладатель потребностей. Не говоря уж о всё той же грамматической несурзике с перепутыванием притяжательных местоимений. Если же предположить, что «его» соотносится с «элемент», — у нас будут все основания поставить авторам этой фразы двойку за знание норм русской стилистики.

Краткое резюме по всему этому локальному анализу: так проводить первичную декомпозицию права не надо.

Устоялось деление права на частное и публичное. Первое де защищает интересы гражданина, второе — государства. Это имеет смысл в единственном случае: когда государство оседлало Общество и свои корыстные интересы обеспечивает за счёт обнищания и обесправливания народа. То есть, как это было в древнем Риме или у нас сейчас. При этом, разумеется, ситуация чисто ленинская: государство — инструмент подавления властвующим классом всех остальных.

Но в подлинно Гражданском Обществе — где государство подчинено Обществу и является слугой народа (выражаясь научно, — подсистемой Общества, его наёмным механизмом управления) — здесь нет никакого резона на подобное деление права. Ибо у государства не может быть никаких иных интересов кроме оптимизации управления Обществом — в его, Общества, интересах, а не в «отдельных» интересах государства. У государства нет никаких иных интересов, кроме обеспечения интересов гражданина — для того его, государство, Общество и нанимает.

Не говоря уж о том, что ни один упёртый «государственник» не посмеет отрицать, что даже при сегодняшнем подходе к декомпозиции права как системы «вылезает» масса рукавов («областей») права, которые вынуждены использовать как нормы «частного», так и «публичного» права.

Следовательно, и этот подход (невзирая на всю его длинную историю — *erga humanum est!*) не содержит в себе разумного начала.

Распространено также разделение права на отрасли и институты. Вот как об этом пишет коллектив авторов [8]: «Отдельные части системы права, разграниченные по предмету правового регулирования, называются отраслями права, под которыми понимается совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. Если нормативное предписание (норма права) есть исходный элемент, основная клеточка права, правовой материи в целом, то правовой институт представляет собой основной элемент отрасли права, первичное, самостоятельное структурное подразделение отрасли, где правовые нормы группируются по их юридическому содержанию». Далее даётся длинный перечень отраслей права: государственное (конституционное), административное, финансовое, трудовое, пенсионное, гражданское, хозяйственное, семейное, земельное, сельскохозяйственное, экологическое, уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, международное. При этом не делается никаких попыток хоть как-то систематизировать этот (вообще-то далеко не полный) перечень. Ясно, что его составил человек, весьма далёкий от навыков системоанализа. А перечень — от представления о едином основании классификации: ведь получился всё тот же (как и в Конституции РФ) оборот «стоны бывают письменные и деревянные». Например, как можно в одном ряду рассматривать международное и уголовное право? Международное право само в виде подсистем содержит все упомянутые «отрасли».

В юридической литературе встречаются отдельные попытки как-то сгруппировать отрасли права. Например, объединив их в несколько групп по формальным признакам: профилирующие отрасли, специальные отрасли, комплексные отрасли. Возможно, в этом и есть некоторый смысл. Но результаты такого объединения далеки от представления права как иерархически выстроенной системы. Продуктивность такой декомпозиции практически равна нулю. В самом деле, что можно извлечь из представления, что некоторые отрасли права «профилирующие», а другие — «комплексные»? Только то, что мы снова встретились с давно известным логическим ляпом: классификацией по разным основаниям — это всё те же «деревянные и письменные стоны».

## **Мы предлагаем принципиально новый подход к декомпозиции права как системы.**

Никто не станет отрицать, что разбиение системы на её подсистемы верхнего (первого) уровня должно выполняться по единому основанию, отражающему глубинную сущность подсистем. Никто не посмеет отрицать, что таким наиболее важным признаком подсистемы является область её функциональных взаимоотношений. Так человеческий организм прежде всего подразделяется на опорно-двигательную систему, нервную систему, пищеварительную систему. Общество подразделяется на подсистему биологического воспроизводства людей, подсистему «материального» (правильнее — вещественного) производства, подсистему общественных отношений, подсистему производства и потребления духовных ценностей (Культуру) и подсистему управления (государство).

И вряд ли кто-либо отважится отрицать, что главной характеристикой подсистемы права является область рассматриваемых ею человеческих взаимоотношений. Вряд ли кто-либо усомнится, что таких главнейших областей три. Во-первых, это область отношений по поводу «материальных» то есть вещественных объектов. Кавычки приходится ставить потому, что в серьёзной научной полемике недопустимо употреблять пусть и привычные для большинства, но принципиально ошибочные термины. Вселенная вся материальна. Нематериального нет ничего. Даже распространённый (к сожалению, не только в фантастике, но и в некоторых научных трудах) термин «антиматерия» должен выжигаться калёным железом и заменяться термином «антивещество». Строго говоря, и информация так же материальна, как и всё остальное. Она *невещественна* — это так.

К тому же пока не видно серьёзных обоснований, способных опровергнуть ту точку зрения, что информация, быть может, — категория мироздания, ещё более основополагающая, чем «материя».

Вторая важная область человеческих взаимоотношений — это общественные отношения. Причём не будем забывать, что правовое государство в Гражданском Обществе — это равнозначный с гражданином субъект права. (Уже поэтому теряет всякий смысл деление права на частное и публичное).

Ко второй области принадлежат производственные, распределительные, потребительные, процессуальные и многие другие отношения, в том числе и уголовные.

Третья главная область человеческих отношений — по поводу того, что выделяет Homo Sapiens из всего остального мира живого. Посмеет ли кто-нибудь отрицать, что это — *интеллект*?

Таким образом, определены три первопорядковые подсистемы права: **Вещественное право, Общественное право, Интеллектуальное право.**

Подсистемами вещественного права являются: гражданское право, арбитражное право, трудовое право, жилищное право, земельное право, предпринимательское право, коммерческое право, финансовое (банковское) право.

К подсистеме права, названной нами **Общественное право**, относятся: конституционное («государственное») право, административное право (вообще-то в большинстве цивилизованных стран такого права нет; оно сохранилось в РФ как тяжкое и, по-видимому, у нас неизживаемое проклятое наследие бывшего СССР), семейное право, «сельскохозяйственное» право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право.

К Интеллектуальному праву относится, прежде всего, та область права, которая призвана защищать *Идею*. То, что у нас этого права до сих пор реально нет — это наш общий позор и наша общая беда. Приведённый выше анализ доказывает, что любая попытка отнести «интеллектуальную собственность» к гражданскому праву — серьёзная системно-логическая ошибка: интеллектуальное право в принципе, по определению, не может быть частью гражданского права, поскольку в системной иерархии интеллектуальное право занимает более высокую ступень, чем гражданское право. (См. рис. 6).

Из этого следует сделать немедленный важный практический вывод: надо предпринять всё возможное, чтобы исключить интеллектуальное право (и, разумеется,

«интеллектуальную собственность» тоже) из сферы действия гражданского права. И предоставить Интеллектуальному праву самостоятельный статус — более высокий, чем у гражданского права. Ибо не владение вещью, а обладание Идеей выделяет человека из мира животных. И если гражданское право — всего лишь вещественные отношения граждан, то Интеллектуальное право сразу же ставит вопрос о взаимоотношениях творца с государством. Уже в силу этого статус Интеллектуального права неизмеримо выше гражданского права.

Важно все необходимые меры предпринять до «выхода в свет» пресловутой четвёртой части Гражданского кодекса.

В первую очередь, следовало бы создать научно-общественный фонд «Регистр интеллектуальной собственности». Его основной целью является выявление идей («интеллектуальной новизны», по определению Международной Академии информатизации) и регистрация объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающая правовую защиту субъекту интеллектуального права — путём выдачи ему соответствующего охранного свидетельства (патента) и размещения необходимых сведений об этом на официальном сайте Фонда в Интернете. Важными видами деятельности Фонда следует признать:

1. Исследование проблемы интеллектуальной собственности в России и в Море.
2. Научное обоснование принципов законодательной защиты идеи как главного объекта интеллектуального права.
3. Подготовка предложений в законодательные органы РФ и других стран Мира о совершенствовании системы интеллектуального права.
4. Пропаганда в научных кругах концепции первоочередной правовой защиты **дефиниции идеи** (см. ниже).
5. Убеждение правоохранительных и правоприменительных органов в необходимости строгой законодательной защиты интеллектуальной собственности, прежде всего, — её главного вида — идеи.
6. Установление научно-деловых контактов с российскими и зарубежными организациями с целью перманентного выявления предполагаемых объектов интеллектуальной собственности и определения принципов построения соответствующих экспертных структур.

Остальные подсистемы Интеллектуального права представлены на рис. 6.

Следует пояснить некоторые детали блок-схемы на рис. 6. Стрелки подчеркивают то обстоятельство, что данные подсистемы второго уровня не являются результатом нашего собственного анализа и не входят в состав нашего предложения. Это «старые», давно сложившиеся «отрасли» права — в составе той бессистемной картины права, которая стала привычной для подавляющего большинства сегодняшних правоведов. Тем не менее, только чрезвычайно необъективный и «упёртый» человек не увидит, насколько аккуратно и убедительно ложатся в предложенную схему декомпозиции системы права даже эти её подсистемы — сложившиеся в результате неуправляемого и нецеленаправленного, фактически стохастического исторического процесса. Конечно, из этого не вытекает, что не следовало бы подумать и о совершенно новом подходе к именованию, структуре и областям действия этих уже сложившихся второуровневых подсистем права. В дальнейшем мы намерены вернуться к этой проблеме.

Что касается международного права, то оно, разумеется, тоже является подсистемой права. Но уже при ином основании декомпозиции — по принципу сферы действия. В этом случае право подразделяется на две подсистемы — регулирующую отношения между государствами (т.е. подсистемами управления разных стран) и множеством частных систем права, регулирующих частное законодательство каждой страны.

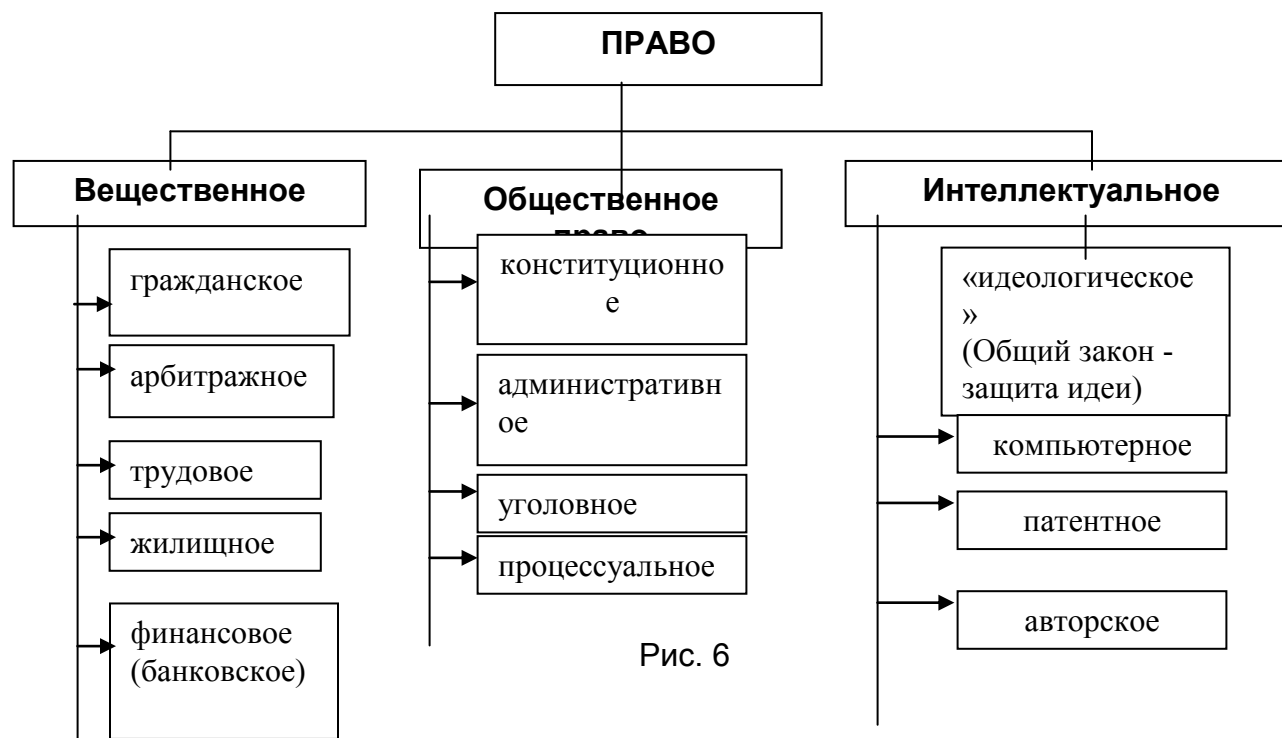


Рис. 6

Структуру Интеллектуального права, показанную на рис. 6, следует считать предварительной. Ибо здесь возможны разные подходы. Можно считать все существующие на сегодня ветви Интеллектуального права его непосредственными подсистемами (что и отображено на рис. 6). Но можно подойти к вопросу и иначе. Как показано в [9], «Из всех видов собственности интеллектуальная собственность — самая важная: кто владеет знаниями, а ещё важнее — методами получения новых знаний, тот и будет определять в конечном итоге структуру общества, распределение собственности, стратегию развития и всё остальное. Из всех видов интеллектуальной собственности самый важный и самый *ценный объект* — *идея*. Её частные реализации — вербальная, техническая и т. п. Эти частные реализации охраняются частными законами — об авторских правах, патентным и т. п. Для охраны самого обобщённого и самого ценного вида интеллектуальной собственности — *идеи* — **необходим обобщённый «основной» закон об интеллектуальной собственности**. Чтобы не смешивать его с Конституцией, назовём его так: **Общий закон об интеллектуальной собственности**».

Общий закон должен в главном защищать *всех создателей интеллектуальной собственности*. Частные законы защищают локальные реализации идеи.

Ныне действующие частные законы нуждаются в кардинальной логико-юридической и системно-лексической корректировке (проще говоря, все они нуждаются в новой разработке). Все частные законы должны подвергнуться подчинительному согласованию с *Общим законом*».

Естественно, каждая из этих областей законодательства обязана вытекать из соответствующей подсистемы права. Рациональная структура Интеллектуального права показана на рис. 7.

Экологическое право нуждается в подробном обосновании (и без сомнения, заслуживает его). Мы рассмотрим его ниже.

Патентное право как подсистема Интеллектуального права имеет право на существование. Хотя и нуждается в серьёзной корректировке.

Самоорганизационное право предлагается взамен разобщённых и подчас противоречивых фрагментов, связанных с правовой защитой товарных знаков, мест происхождения товаров, фирменных и **всех прочих** наименований, которые могут возникать в процессе информационно-сотовой самоорганизации и в последующем самоуправлении Общества.

Об авторском праве (как это ни парадоксально!) сказать что-либо положительное весьма затруднительно. По нашему мнению, оно на деле не защищает ничего. Ибо невозможно защищать форму в отрыве от содержания, причём содержание и определяет форму и является неизмеримо более важным компонентом *любого произведения* сравнительно с его формой. Судебная система в области авторского права ничего лучше, чем ориентация на прецедент предложить не может (см. «ИС. Авторское право и смежные права» № 10 – 11, 2002. А. Птушенко. Огрехи Закона об авторских правах). А также раздел «Критика закона об авторских правах» в настоящем учебнике.

Проведённый нами анализ свидетельствует о необходимости коренной перестройки авторского права. (Невзирая ни на какие конвенции и соглашения, которые, к сожалению, ситуации ничуть не улучшают и путаницы в системе понятий не устраняют).

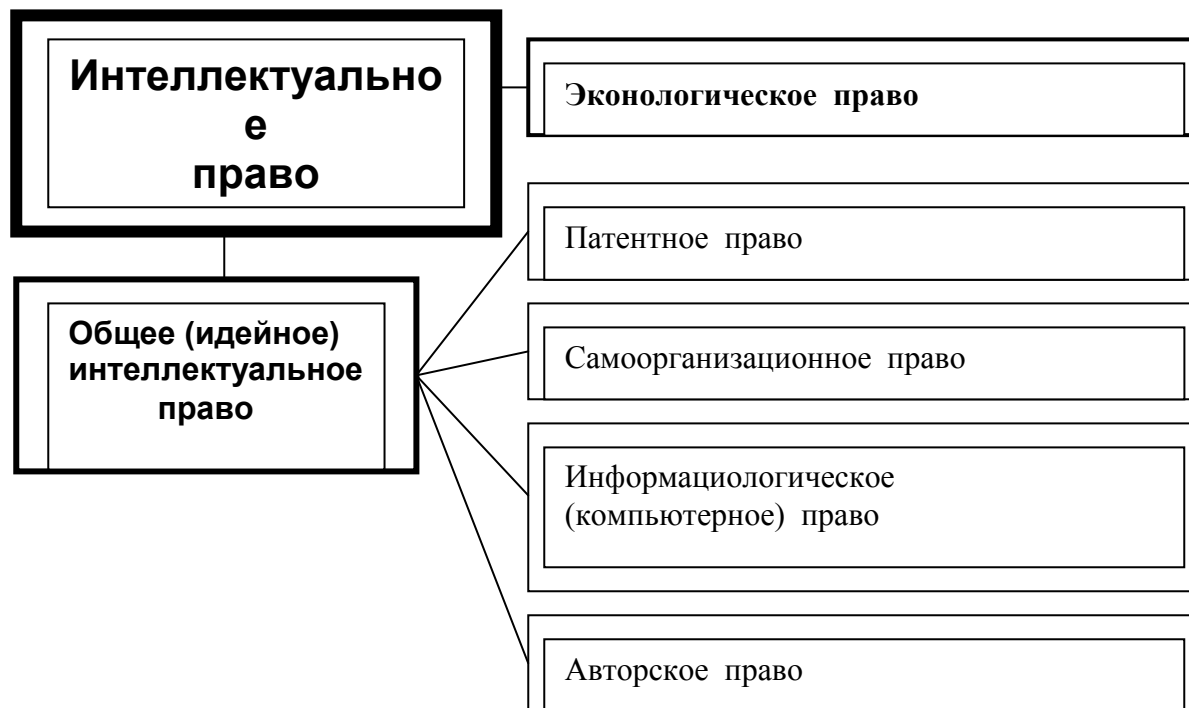


Рис. 7

Теперь мы подошли к важному объекту исследования — «компьютерному» праву. Придётся решать вопрос — снимать ли с него кавычки. Строгий ответ, на мой индивидуальный взгляд, — «да». Но не для того, чтобы предложить его в качестве названия этой новой и чрезвычайно важной области права.

Её разумнее (и обоснованнее) назвать так: **Информациологическое право**. После всего, о чём мы уже говорили и будем говорить ниже — об ошибках в толковании термина *информация* и о развитии новой науки *Информациологии* — становится понятным, как нам представляется, предпочтение второго термина первому. В отличие от вездесущей и далеко не всеми разумно понимаемой «информации», Информациология представляет собой чёткую и определённую науку, совершенно прозрачно связанную с определённой областью человеческой деятельности. Принятие этого названия уберёжёт человечество (и Россию в частности) от множества уже устоявшихся и от ещё большего множества возможных дальнейших ошибок.

Тем не менее (разбираясь в гидравлике и аэродинамике) мы — за «безударный вход»: на первых порах разумно сохранить привычное многим слово «компьютерное» — как поясняющий, демпфирующий, а также излишне укоренившийся элемент тезауруса. То есть — в скобках. (Не повторяя часто встречающейся ошибки типа «информационно-компьютерное»).

О содержании этого права надо говорить отдельно.

Создателям информациологического права предстоит колоссальная работа. Прежде всего надо отработать основные принципы этого права. Один из них — право на информацию. Мы будем продолжать пользоваться этим термином ввиду того, что он стал привычным для огромного количества людей. Если чётко представлять себе все наши положения о соотношении сообщения и реализованной информации, о тезаурусе и имманентных свойствах реализованной информации — то есть помнить обо всём, о чём мы подробно рассказали ниже, — в этих условиях использование этого термина (по крайней мере, на первом этапе распространения системной концепции права) можно признать допустимым (при категорическом запрещении, разумеется, таких вздорных словосочетаний как «средства массовой информации»).

Статья 29 Конституции РФ сформулирована очень плохо («Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»). Ведь всё дело в том, кто и по каким критериям будет устанавливать эти «законные способы». Особенно, когда речь пойдёт об Интернете или других международных коммуникационных сетях. Ясно, что нашим юристам, получившим свои дипломы из рук Кириллова-Угрюмова или Карлова (т.е. от несуществующей ныне и как бы дезавуированной власти — от в принципе порочной юриспруденции), — таким «специалистам» сформулированная нами проблема не по плечу и не по зубам. Требуются специалисты совершенно иного уровня подготовки и широты эрудиции. Ясно, что в информациологическом праве не место таким нечётким и малообязывающим декларациям как «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». «Массовая информация» — это не только системно-логический нонсенс (см. ниже), это вообще маловразумительное словосочетание: можно ли дать некий разумный критерий массовости (вспомните знаменитую логическую задачу о «куче»). Не говоря уж о том, что подобный «юридический» выверт как бы не гарантирует свободы всей «немассовой» информации. Принципы права вообще не могут формулироваться как прекраснодушные декларации маниловского толка, они должны доводить каждое положение до чётко сформулированных условий и требований к его реализации.

А запрещение цензуры «в общем виде», без однозначной дефиниции рассматриваемого понятия — это просто безответственное сотрясение воздуха. Это особенно наглядно в условиях всё того же Интернета. Чья цензура запрещается? В каких объёмах, при каких условиях? Как это скажется на правах пользователя? — всё это миллионная доля вопросов, которые придётся решать в рамках одного из направлений (подсистем) информациологического права.

Отдельная проблема — защита первичной информации. В том числе и от противоправных покушений на неё со стороны государства. Права создателя должны занять в современном праве подобающее им место. Государство должно зависеть от творца, а не творец от государства. Ибо государство в современном обществе — слуга народа (см. ниже).

Заново следует рассмотреть и такую проблему, как регламентация доступа к персональным данным.

Нам же остаётся закончить наш теоретический анализ системы права. Вполне логично признать, что подсистемы информациологического права будут соответствовать подсистемам информатики как науки (см. ниже). На рис. 8 приведена соответствующая блок-схема.





Рис. 8

Подсистемное право покрывает область отношений, возникающих по поводу управления системами (что в структуре Информатики соответствует подсистеме *Кибернетика*).

Объектное право (область *Информатики*) регулирует правоотношения создателей и потребителей «железа», «софта» и всех объектов, обеспечивающих их распределение и эксплуатацию.

Коммуникационное право (область *Информологии*) регулирует все сетевые отношения, в том числе возникающие в Интернете.

Номогенезное право — так же как на своём уровне наука *Информоника* — обеспечивает область изучения и наименования внутренних законов информатики.

Нам остаётся свести воедино все вышерассмотренные фрагменты общей картины. Результаты этой операции представлены на рис. 9. Он ещё раз свидетельствует, что системный подход даёт удовлетворительный результат там, где все иные подходы ничего кроме сумятицы и неразберихи предложить не в состоянии.

В связи со сказанным ещё раз сопоставим две ситуации. Первая: нормы права создают специально обученные, широко эрудированные, владеющие методологией системного анализа специалисты (разумеется, не с «советскими» дипломами). Эти нормы создаются на базе серьёзных комплексных исследований во всех имеющих отношение к проблеме междисциплинарных областях — с учётом всех сложных и многомерных межсистемных связей. Эти положения и признаются Обществом в качестве права. Которое и служит направляющими косинусами (кому понятнее так — лекалом) для последующего законодательства. Здесь **право — источник закона**.

Вторая ситуация, ныне действующая: «закон — источник права». Проще говоря, некое случайное сборище разнородных людей, мало приученных к мышлению системными, философскими, формально-логическими категориями; обуреваемых чисто лоббистскими устремлениями во имя интересов разномастных кланов и экономико-политических группировок, в спешке и суете, в мельтешении взаимоисключающих мелочных предвыборных амбиций и желания угодить многим «вышестоящим»; в малопочтенной — вплоть до физической — борьбе принимают некий кукишобразный текст и называют его законом. Который, если его, вполне возможно, тут же не отменит Конституционный суд, умрёт через год при очередной смене власти в стране. И после всего этого находятся «теоретики», призывающие нас признать этот «кукиш в кармане» источником права.

Думается, любой непредвзятый человек предпочтёт первую ситуацию второй.

Рассмотрим конкретный пример. В последние годы очень активизировались телефонисты, непрерывно повышающие тарифы и с упорством, достойным лучшего применения, не оставляющие поползновений загнать небогатого российского интернетчика в яму «повреждения». Ждать чего-либо разумного от отечественного правоверного

правоведа, как показывает жизнь, сегодня не приходится. И никакие якобы «антимонопольные» законы не помогут.

Однако Общество заинтересовано не столько в выделенном процветании телефонистов, сколько в собственном развитии и безопасности. Следует глубоко и системно разобраться, могут ли частные интересы подсистемы противоречить интересам метасистемы. Любой системоаналитик знает: не могут. Остаётся провести исследование и показать, насколько развитие российского Интернета важнее для Общества, чем снижение удельной платёжеспособности работника телефонной связи. Под этим «насколько» мы подразумеваем не общие разговоры и прекраснодушные декларации, а чёткие числовые (бога ради, не «цифровые»!) данные сравнительного экономико-эффективного анализа (см., например, [10]). И именно эти данные фиксируются Обществом как норма права. Из которой и произрастёт затем закон, умеряющий частнособственнический пыл работников связи, — в интересах Общества в целом (но не государства!).

Ещё более важный пример — налог на потреблённые невозполнимые природные ресурсы. И здесь только опытный эконолог (т.е. эколого-экономико-юрист — «в одном флаконе») способен правильно сформулировать задачу и дать её оптимальное — эколого-экономико-правовое решение. Это решение Общество зафиксировывает в виде нормы права. По этой норме государство (его законодательная ветвь) и будет кроить соответствующий закон. При этом требования к законодателю снижаются до доступного на сегодня уровня — определяемого нашей далеко не безупречной сегодняшней системой выборов «представительной власти».

Как видите, структура права как системы в немалой степени определяет и требования к современному правоведа, и регламент регулирования всех общественных отношений, и формы организации эффективной системы управления Обществом.

Попутно напомним: не дело исполнительной власти — писать законы. Её дело — исполнять. Удивительно, что сегодня ни один «правоверный» юрист не замечает этой сложившейся у нас противоправной практики. Противоречащей даже ущербной ныне действующей Конституции РФ.

Так что есть из-за чего бороться с отжившими взглядами и привычками.

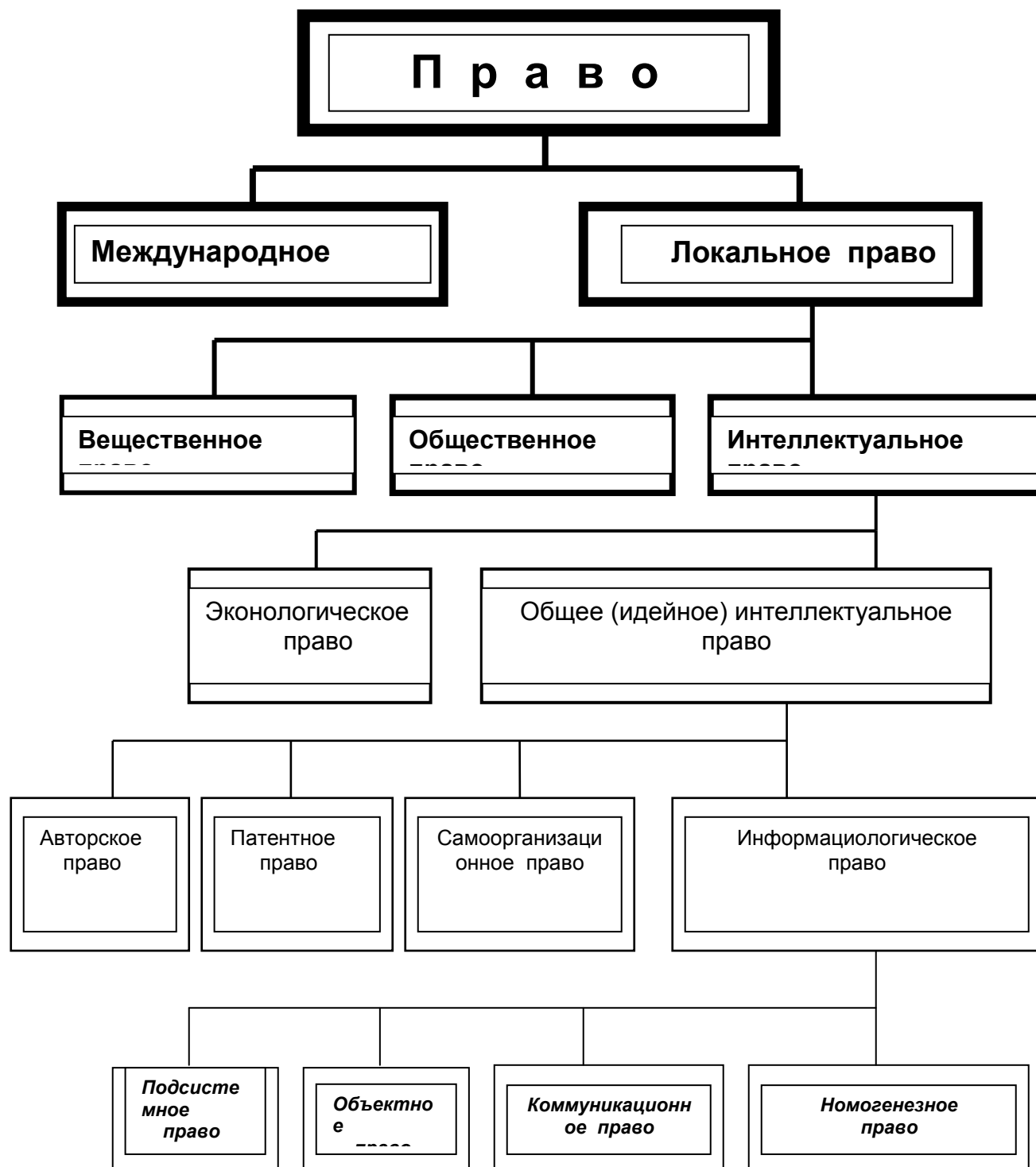


Рис. 9

Естественно, международное право подразделяется на те же подсистемы, что и локальное право.

## **5. Экологические корни Права**

Экологии у нас не повезло не меньше, чем праву. Мало кто отдаёт себе отчёт, что это наука (определённая область Науки). В ходу нелепые выражения «экология души», «в этом районе плохая экология», «экология окружающей среды» и т. п. Как справедливо заметил Козьма Петрович Прутков, люди вообще колбасам подобны — чем их начиняют, то они и носят в себе. Почему-то они с поразительным упрямством держатся за свои типовые ошибки и распространённые заблуждения. «Одеть» вместо правильного «надеть». «Секвестр бюджета», «исполнительная и представительная власть», «в эпицентре событий» и прочие надоедливые благоглупости. В том числе и не к месту употребляемое слово «экология».

На самом деле, экология — наука о надорганизменных системах. Биология изучает Жизнь в диапазоне от молекулы (молекулярная биология) до организма. Свойства систем организмов — популяций, видов, биоценозов, экосистем, биогеоценозов, биосферы — объекты экологии. Можно говорить об экологии человека как вида — *Homo sapiens*; можно изучать взаимодействие человека с окружающей средой (ноосфера Вернадского), можно заниматься социальной экологией — взаимодействием подсистем Общества между собой и с Природой. Очевидно, в последнем случае экология непосредственно выходит на Право.

Большая часть современных учёных пришла к выводу: человечество не выживет на Земле, если в ближайшие десятилетия не изменит своего отношения к Природе и к конечным целям развития земной Цивилизации.

На наш взгляд, чтобы выжить, человечеству прежде всего необходимо осознать неадекватность общепринятых основ экономической теории, неэффективность устоявшихся подходов к организации управления обществом. Необходима новая концепция Правового государства как подсистемы Гражданского общества. Необходимо осознать: невозполнимые природные ресурсы не могут стихийно расточаться во благо узких группировок, лишая при этом всё остальное человечество права на существование. Необходимо отказаться от парадигмы «природоохранных мероприятий», заменив её принципом коэволюции и взяв на вооружение лозунг: «Неэкологичная экономика не имеет права на существование». Необходимо признать: государство в XXI-м веке не может быть ничем иным, как только слугой народа — наёмным механизмом управления обществом. Иначе говоря, необходим системный подход к комплексной проблеме выживания человеческой цивилизации на планете Земля. Новая Концепция характеризуется, по нашему мнению, следующими основными чертами.

1. Революционным путём проблем земной цивилизации не решить: история наглядно показала, что всегда готовят революцию недоучившиеся фанатики, свершают революцию полукриминальные маргиналы, а пользуются её плодами мошенники и мерзавцы. Религия также не приспособлена к решению серьёзных задач и сама нередко вызывала братоубийственные войны. Остаётся наука. Конечно, и ей самой прежде придётся отказаться от схоластики и от привычки работать на предрержащие власти.
2. Человечество выживет лишь в том случае, когда успеет до начала апокалипсиса развить эффективную, независимую от любых властей, науку и приучится следовать её установкам, игнорируя призывы разномастных политиканов. Следовательно, необходима система образования — признанная важнейшей подсистемой Общества: снабжаемой в первую очередь (даже если это ослабит все остальные подсистемы, в особенности чиновный клан государства).

3. Над всеми привычными ветвями государственного механизма (судебной, законодательной, исполнительной) должна стоять Концептуальная ветвь, формируемая научными методами на базе оптимизированных научных и массовых коммуникаций и определяющая главные «направляющие косинусы»: конечные цели общества, оптимальные пути к этим целям, запреты и ограничения, которые Общество налагает на своё государство.
  4. Система «государственного образования» страдает множеством органических пороков и «по определению» не может решить задачу, сформулированную в п. 2. Следовательно, необходима новая система образования, неразрывно связанная с Наукой, контролируемая самим сообществом учёных, ограждённая законодательно от любого вмешательства государственного чиновника. Ведь поставленная задача требует «обратного соотношения»: не государство диктует науке свои требования, а Наука предписывает (через систему образования и просвещения) государству нормы и правила поведения. **Наука создаёт право.**
  5. Главнейшим вопросом для самоорганизации Общества необходимо признать проблему принадлежности невозполнимых природных ресурсов. И только наука может обосновать, какие ресурсы и при каких условиях могут находиться в частной собственности. Наука должна обосновать перечень природных объектов, которые ни при каких условиях не могут принадлежать к частной собственности. Эти установки наука доводит до общественного мнения через подсистемы образования-просвещения и массовые коммуникации. **Эта задача — важнейшая для теории права.**
  6. Поскольку основой доктрины выживания человечества является неукоснительный переход всех без исключения областей человеческой деятельности на принципы рационального природопользования, Наука должна сформировать принципиально новые основы теории Права и государства, а также экономической теории. Корни Экономики, корни Права должны вырастать из принципов Рационального Природопользования. Именно это и составит предмет новой науки — *экологии*.
  7. Из вышеизложенного можно сделать единственный разумный вывод:
    - Необходимо немедленно развивать новые комплексные области науки — информатику, системный анализ, экологию, науковедение и культуроведение.
    - Необходимо безотлагательно создать Международную Академию Экологии.
    - Необходимо начать развитие системы непрерывного комплексного образования, способной решить вышесформулированные задачи.
    - Эта новая образовательно-просветительная система должна ориентироваться на наднациональные ценности и обеспечивать подготовку докторов и магистров международной квалификации.
    - Необходимо принять ряд законов, направленных на правовую защиту Интеллектуальной собственности и создание единого информационно-терминологического пространства, постепенно охватывающего как РФ, так и страны СНГ и всего остального мира.
- При этом было бы ошибкой не учитывать геополитическую ситуацию в мире.

### А) Проблемы геополитики

Самое страшное проклятие в древнем Китае — пожелание: «Чтобы жить тебе в эпоху перемен!». Сегодня все мы — не одна Россия, а всё человечество — вступили в такую эпоху. Эпоху смены парадигм, пересмотра основ мироздания.

Наивно полагать, что кризисы охватили только Россию, а на пресловутом Западе всё в лучшем виде. Ещё наивней — уверять себя и других, что свои проблемы Россия способна решить сама. Не подумайте однако, что я намерен снова развивать эту тягомотину о «внешних» инвесторах, кредитах и займах. Отнюдь. Речь совсем о другом: пора, наконец, вспомнить о теореме Гёделя. Её суть, как известно, в том, что в любой системе возникают проблемы, в рамках этой системы принципиально не решаемые и требующие поиска решения в рамках надсистемы. Применительно к России это означает, что прежде надо думать об общечеловеческих проблемах (называемых сегодня «глобальными»), и лишь во вторую очередь — о своих внутренних распрях и раздорах. Есть, конечно, и обратная сторона медали. Наивно думать, что Запад однозначно хочет мира.

(продолжение следует)